分类号 D9 学校代码 10590
UDC 342.9 密 级 公开

深圳大学硕士学位论文

论不予行政处罚事由的类型化重构
——基于行政法律责任状态的视角展开

学位申请人姓名 李曼琪
专 业 名 称 法学
学院（系、所） 法学院
指导教师姓名 高俊杰副教授

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

对不予行政处罚事由进行类型化研究，形成一个逻辑清晰、规范有序的不予行政处罚体系，是促进行政执法规范化的现实需求，也是我国行政处罚制度发展的必然要求。行政处罚决定的作出和实施，围绕着行政法律责任的产生和实现展开。从该视角出发，根据行政法律责任的“未产生、产生后消灭、产生后持续”这三种状态，可以把不予行政处罚事由分为违法构成缺失事由、行政法律责任消灭事由以及免予行政处罚事由。其中，违法构成缺失事由包含实质违法性缺失与有责性缺失两类情形。实质违法性缺失的典型情形主要有正当防卫、紧急避险、法令行为、义务人冲突、被害人承诺等，有责性缺失的典型情形主要有责任能力缺失、责任条件缺失。行政法律责任消灭事由主要包含处罚权丧失与处罚对象灭失两类情形。处罚权丧失主要有逾越行政处罚追诉时效，以及法律适用从轻后，原违法行为在新法中不再视为违法或者不再受处罚的情形；处罚对象灭失主要有作为当事人的自然人死亡、以及作为当事人的法人或者其他组织终止，无权利义务承受者两种典型情形。免予行政处罚事由主要包含法定免罚事由与裁量免罚事由。当前，我国行政处罚领域常见的法定免罚事由为“无危害性不罚”和“一事不再罚”；常见的裁量免罚事由主要有“首违可以不罚”以及其他“附条件可以不罚”，如受害人和解并履行赔偿义务可以不罚、主动参加社会服务可以不罚等。

关键词：不予行政处罚事由；行政法律责任；违法构成缺失事由；法律责任消灭事由；免予行政处罚事由

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In order to promote the standardization of administrative law enforcement and perfect the administrative penalty system, it's of great significance to conduct a typological study of the reasons for not imposing administrative penalties, and to form a logical and clear, orderly system of not imposing administrative penalties. The making and implementation of administrative penalty decisions revolves around the arising and realization of administrative legal responsibility. From this perspective, in terms of the different states of administrative legal responsibility, the reasons for not imposing administrative penalties can be classified into the grounds for lack of illegal composition, the grounds for extinguishment of administrative legal responsibility and the grounds for exemption from administrative penalty. Among them, the grounds for lack of illegal composition includes the kinds of substantive illegality deficiency and liability deficiency. The typical situations of substantive illegality deficiency mainly include justifiable defense, emergency avoidance, ordinance behavior, obligation conflict behavior, commitment behavior, etc. The typical situations of liability deficiency mainly include lack of administrative responsibility capacity and the lack of subjective factors. The grounds for extinguishment of administrative legal responsibility mainly includes two kinds of situations: the extinction of the power of administrative penalty and the loss of the punishment object. The typical cases of the extinction of the power of administrative penalty include the cases of exceeding the statute of limitations on administrative penalties, and the cases where the violation is no longer considered illegal or no longer punishable under the new law after the application of the law in a lighter manner. The typical cases of the loss of the punishment object includes two typical situation：a party who is a natural person dies., and a party who is a legal person or any other organization is terminated, there is no any other legal person or organization to assume its rights or obligations. The grounds for exemption from administrative penalty mainly include statutory exemptions and discretionary exemptions. The common statutory exemptions includes "impunity without harm" and “non repeated penalty” Besides, common discretionary exemptions mainly includes "first violation can be impunity" and other

中国知网 https://www.cnki.net

conditional impunity, which includes that the party concerned reconciles with the victim and fulfills the obligation of compensation，and takes the initiative to participate in social services.

Key word: the Reasons for not Imposing Administrative Penalties; Administrative Legal Responsibility; the Grounds for Lack of Illegal Composition; the Grounds for Extinguishment of Administrative Legal Responsibility; the Grounds for Exemption from Administrative Penalty

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

绪论.....1
一、问题的缘起.....1
二、研究现状及评述.....2
(一)研究现状.....2
(二)评述:总结与反思.....6
三、研究的意义与价值.....7
四、研究的思路与方法.....8
(一)研究的思路.....8
(二)拟采用的研究方法.....8
第一章 不予行政处罚事由的类型化价值、逻辑与具体安排.....10
第一节 类型化的价值.....10
一、不予行政处罚事由类型化的理论价值.....10
二、不予行政处罚事由类型化的实践价值.....10
第二节 类型化的逻辑:行政法律责任状态的视角.....11
一、对既有类型化思路的辨思.....11
二、基于行政法律责任状态视角的类型化思考.....12
第三节 类型化的具体安排.....13
一、违法构成缺失事由.....13
二、行政法律责任消灭事由.....14
三、免予行政处罚事由.....14
第二章 违法构成缺失事由.....16
第一节 实质违法性缺失之不罚.....16
一、正当防卫.....16
二、紧急避险.....20
三、法令行为.....23
四、义务冲突.....24
五、被害人的承诺.....25
第二节 有责性缺失之不罚.....26
一、责任能力缺失.....26
二、责任条件缺失.....27
第三章 行政法律责任消灭事由.....33
第一节 行政处罚权丧失.....33
一、逾越行政处罚追诉时效.....33
二、法律适用从旧从轻.....36

中国知网 https://www.cnki.net

第二节 行政处罚对象灭失.....37
第四章 免予行政处罚事由.....39
第一节 法定免罚事由.....39
一、无危害性不罚.....39
二、一事不再罚.....49
第二节 裁量免罚事由.....52
一、首违可以不罚.....52
二、附条件可以不罚.....56
结语.....58
参考文献.....60

中国知网 https://www.cnki.net

绪论

一、问题的缘起

《中华人民共和国行政处罚法（2021）》回应了全面依法治国、建设法治政府的时代呼声，对行政处罚的诸多制度进行了优化重构。其中，新增的“首违不罚”、“当事人有主观证据证明没有主观过错不罚”、“从旧兼从轻”等条款，扩宽了不予行政处罚制度的适用空间。与此同时，在行政处罚具体领域的立法与实践中出现的不予行政处罚的情形，远比《行政处罚法》之规定更为多样和具体化。例如，在医疗急救相关立法与实践中，驾驶人因让行或者参与救助患者导致违反交通规则的，往往对驾驶人不予行政处罚。再如，根据《广东省劳动保障监察条例》第四十二条规定，对于金钱给付等投诉案件，双方当事人调解达成一致意见并当场全部履行的，行政机关可视情节轻重对用人单位不予处罚或者减轻处罚。

对于复杂多样的不予行政处罚事由，当前《行政处罚法》及相关法律规范并未进行类型化归纳与体系性阐释，而仅进行简单列举。因此，不予行政处罚事由的范围与适用仍难言明确，行政处罚执法实践中对不予行政处罚事由普遍存在着考虑不足的问题，从而引起了大量的行政纠纷。一方面，由于不予行政处罚事由繁多，行政机关往往在适用上出现混乱，比如将不符合违法构成要件的情形、法定免罚情形与裁量免罚情形相混淆；另一方面，正如学者谢红星所指出的，从总体来看，执法机关和一线执法人员仍然普遍抱有“能罚则罚、不罚失职”的心态，对不予行政处罚顾虑重重。[1]对不予行政处罚事由缺乏重视、适用混乱，对于违反行政管理秩序的行为只罚不管、以罚代管，一方面易于造成行政处罚的不合法、不合理，有损相对人的合法权益；另一方面不利于引导行为人积极改正轻微违法行为，反而易于激化社会矛盾，造成更为严重的违法及犯罪。

随着当前法治国家、法治政府、法治社会建设的推进，我国对行政权的行使提出了更高的要求。在维护行政管理秩序的同时，实现公平正义和保障人权的目标，是新时代行政处罚的应有之义。与此同时，我国正面临着从控制行政向服务行政的转型，行政机关在行政执法中的角色，不能仅限于秩序的维护者，更要成为经济与社会的促

[1] 谢红星：《不予行政处罚的法理——围绕<行政处罚法>第33条展开》，载《广东社会科学》2022年第2期，第242页。

中国知网 https://www.cnki.net

进者。这引发了行政处罚功能由“等价制裁”向“制裁为主、预防为辅”的功能变迁，更多“非正式执法手段”等柔性执法方式进入公众视野。然如上所述，行政执法中普遍存在对不予行政处罚事由考虑不足、适用错误的问题，行政处罚的正当性难以得到保障。正确认识、系统把握不予行政处罚，对于提高行政执法的规范性、保护行政相对人的合法权益具有重要意义。要体系地认识和把握不予行政处罚事由，对不予行政处罚事由的类型及适用展开研究是必由之路。

二、研究现状及评述

（一）研究现状

（1）不予行政处罚事由的概念与范围

对不予行政处罚事由进行界定，是对其展开体系研究的前提。从语义解释而言，不予行政处罚，是指出于特定原因，对违反客观法律规范的行政相对人，不适用行政处罚。这一特定原因即为不予行政处罚的事由。《行政处罚法（1996）》规定的不予行政处罚事由主要有以下几种：一是不具有责任能力，二是轻微违法行为，三是逾越法定追究时限。[2]因此，《行政处罚法》修订前，学者对不予行政处罚事由的讨论主要围绕上述三种情形展开。除以上情形以外，许多学者主张，当事人正当防卫、紧急避险的，对当事人不适用行政处罚；[3]少数学者主张，因行政机关及其工作人员的责任实施的违法行为，对当事人不适用行政处罚；[4]也有学者主张，因生理缺陷的原因而违法的，对当事人不予处罚；[5]晏山嵘认为，处罚阻却事由还包括法令行为、正当业务行为、被害人承诺、推定承诺、义务冲突、自救行为、自损行为、不可避免的违法性认识错误等。[6]2021 年修订的《行政处罚法》在《行政处罚法（1996）》的基础上，对不予行政处罚事由进行了扩充。[7]此外，在行政处罚的具体领域，出现了更为多样和具体的不予

[2] 《行政处罚法（1996）》第二十五条规定：“不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教”；第二十七条第二款规定：“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”；第二十九条规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。”

[3] 汪永清：《关于应受行政处罚行为的若干问题》，载《中外法学》1994 年第 2 期，第 24 页；王志平：《论行政处罚适用的构成要件》，载《现代法学》1997 年第 5 期，第 88-89 页；关保英编：《行政处罚法新论》，中国政法大学出版社 2007 年版，第 166 页；曹康泰：《行政处罚法教程》，中国法制出版社 2011 年版，第 97 页；晏山嵘：《行政处罚实务与判例解释》，法律出版社 2019 年版，第 242-243 页。

[4] 汪永清：《关于应受行政处罚行为的若干问题》，载《中外法学》1994 年第 2 期，第 20 页；关保英：《行政处罚法新论》，中国政法大学出版社 2007 年版，第 166 页。

[5] 王志平：《论行政处罚适用的构成要件》，载《现代法学》1997 年第 5 期，第 88-89 页；关保英：《行政处罚法新论》，中国政法大学出版社 2007 年版，第 166 页。

[6] 晏山嵘：《行政处罚实务与判例解释》，法律出版社 2019 年版，第 241-251 页。

[7] 根据《行政处罚法（2021）》第三十七条：“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但

中国知网 https://www.cnki.net

行政处罚事由。通过对当前的《行政处罚法》、行政处罚性法律规范以及行政处罚案例进行梳理，可以发现我国不予行政处罚事由主要如下。一是《行政处罚法》中明确的事由，主要包括责任能力缺失、责任条件缺失、逾越行政处罚追诉时效、法律适用从旧从轻、无危害性不罚、一事不再罚、首违可以不罚等；二是从行政处罚性法律规范中可归纳得到的事由，主要包括正当防卫、紧急避险、法令行为、行政处罚对象灭失、附条件可以不罚等；三是从法理中可以推演出的、并在实践中得到广泛认可和运用的事由，包括义务冲突、被害人承诺等。

学者对我国台湾地区和奥地利、德国、俄罗斯等国的处罚免罚事由进行了研究。可以发现，各国家和地区的不予行政处罚制度既有共性又各具特点。在行政处罚领域，得到广泛承认的不予行政处罚事由包括正当防卫、紧急避险、行为人不具有责任能力、违法追究期限届满等。同时，各国家和地区在不予行政处罚事由制度的安排上也有所差异。在我国台湾地区，行政机关对于行政处罚具有一定裁量权，可视具体情节对于不知法而违法的、防卫和避险过当的行为、罚款金额在三千元台币以下且其情节轻微的行政行为不予行政处罚。奥地利的行政处罚制度明确了对于因不知法而违法的行为、受唆使和援助而实施的违法行为以及预备违法行为等不罚事由。德国的行政处罚制度明确了对于新法不再视为违法的、过失违法的、因不知法而违法的和未遂的违法行为等不罚事由。俄罗斯的行政处罚制度则明确了对于轻微违法行为的免罚。[8]

（2）不予行政处罚之类型探讨

对多样化的不予行政处罚事由展开体系研究，重点在于以类型化的方法，对众多事由进行分析和归纳。目前，对于不予行政处罚事由，体系研究的成果较为少见，其分类与适用尚未达成共识。但从整体来看，对于不予行政处罚事由的分类主要形成以下观点：

一是以是否构成违法行为作为分类的标准，将不予行政处罚事由分为违法性免除事由和处罚免除事由。汪永清认为，对于不予行政处罚事由，要区分其属于行为违法性的免除，抑或是行政处罚的免除。[9]行为违法性的免除是指某一行为在客观上或者外形上具备应受行政处罚行为的构成要件，但由于法定原因而免除其违法性，从而对相

是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”

[8] 熊樟林编：《中外行政处罚法汇编》，北京大学出版社 2021 年版，第 21-232 页。

[9] 汪永清：《关于应受行政处罚行为的若干问题》，载《中外法学》1994 年第 2 期，第 24-25 页。

中国知网 https://www.cnki.net

对人不予行政处罚；行政处罚的免除是指某一行为属于违法行为，但由于其具备某种特定的免予处罚条件，行政机关对其免予处罚，该免予处罚并不能改变行为的性质。王志平将“行为违法性的免除”归纳为“不予处罚”，将“处罚的免除”归纳为“免予处罚”。[10]曹康泰则进一步阐述了这两个概念的涵义，主张不予行政处罚是一个行为完全不具备构成行为违法行为的要件，或者仅在形式上具备客观要件，但其违法性因法定事由得以免除，因而对相对人不给予行政处罚；免予处罚，是指某一行为已然满足行政违法行为的构成要件，构成违法行为，本应对其给予处罚，但由于法定事由的存在或者立法的特殊考虑，放弃追究行为人的法律责任。[11]

许多学者对这一分类标准予以认可，并赞同将正当防卫、紧急避险、当事人不具有责任能力作为行为违法性免除的事由。除以上事由外，该分类标准下的具体事由仍存在一定争议。汪永清认为，因行政机关或者行政机关工作人员的责任而实施的行为，属于免除违法性的行为。[12]王志平主张，因行政管理人的过错、因国家法律、法规和政策及其他因素而违法的，应免除行政处罚，但并不免除行为的违法性；因生理缺陷而违法的，免除行为的违法性。[13]此外，王志平、曹康泰、尹培培等认为，违法行为轻微并及时纠正，没有危害后果的，该行为不具有可罚性，因此行为的违法性得以免除。[14]而对于《行政处罚法（2021）》新增的“当事人有根据足以证明无主观过错不罚”这一条款，有学者主张，该条款将当事人自证无主观过错作为阻却违法行为成立的事由，由此主观过错成为行政违法行为构成要件考量因素之一；[15]也有学者主张，当事人自证无过错并非阻却违法行为成立的事由，而是法定免除行政处罚的事由。

二是不设统一的分类标准，而根据不同事由的特点，凝练出不同的类型。晏山嵘将不予行政处罚事由分为四个类型，即“正当化的”、“可赦免的”、“可谅解的”以及“不需罚的”处罚阻却事由。晏山嵘主张，正当化的处罚阻却事由是指虽然表面上具备了违法行为的特征，但实质上不构成违法行为的情形，包括正当防卫、紧急避险、法令行为、正当业务行为、被害人承诺、推定承诺、义务冲突、自救行为、自损行为、

[10] 王志平：《论行政处罚适用的构成要件》，载《现代法学》1997 年第 5 期，第 88-89 页。
[11] 曹康泰：《行政处罚法教程》，中国法制出版社 2011 年版，第 97 页。
[12] 汪永清：《关于应受行政处罚行为的若干问题》，载《中外法学》1994 年第 2 期，第 24 页。
[13] 王志平：《论行政处罚适用的构成要件》，载《现代法学》1997 年第 5 期，第 88-89 页。
[14] 王志平：《论行政处罚适用的构成要件》，载《现代法学》1997 年第 5 期，第 88-89 页；曹康泰：《行政处罚法教程》，中国法制出版社 2011 年版，第 98 页；尹培培：《不予行政处罚论——基于我国<行政处罚法>第 27 条第 2 款规定之展开》，载《政治与法律》2015 年第 11 期，第 149 页。
[15] 杨东升、刘恺：《论行政处罚主观过错归责原则——〈行政处罚法〉（修订二审稿）第 31 条评析》，载《南昌大学学报》2020 年第 6 期，第 79 页。

中国知网 https://www.cnki.net

不可避免的违法性认识错误、意外事件等。可赦免的处罚阻却事由是指行为虽然违反法律，但情有可原，行政处罚主体基于期待可能性的原理，可以对当事人予以赦免、不予处罚的事由，包括假想防卫、偶然防卫、防卫不适时、防卫过当、假想避险、当事人不具有责任能力等情形。可谅解的处罚阻却事由是指行为虽然违反法律，但该行为是基于民间纠纷等原因引起，情节比较轻微，经调解双方达成和解，行政处罚主体可以考虑不予处罚的情形。不需罚的处罚阻却事由是指行为虽然违反法律，但情节轻微或者社会秩序已趋于平复，行政处罚主体基于便宜原则或者效率原则，认为不需要或者不必要给予处罚的情形，包括“无危害性不罚”以及超过处罚时效的情形。[16]

此外，有学者仅对部分不予行政处罚事由进行了区分研究。例如，熊樟林以应受行政处罚行为的三阶层构造作为分析框架，将阻却应受行政处罚行为成立的事由分为违法性阻却事由与责任阻却事由两类。违法性阻却事由包括正当防卫、紧急避险、执行职务、义务冲突、被害人承诺等情形；责任阻却事由包括相对人不具有责任能力的情形。具有阻却事由的，应受行政处罚行为不成立，不得给予行政相对人行政处罚。[17]周苏湘同样围绕应受行政处罚行为的阶层构造展开，将不予行政处罚事由划分为行政不法行为不成立之情形、可受非难性欠缺的情形以及行政处罚必要性阙如的情形。其中，当事人无主观过错，可解读为行政不法行为不成立的情形；当事人无责任能力，可解读为可受非难性欠缺的情形；违法行为轻微并及时改正，可视为行政处罚必要性阙如的情形。[18]谢红星则对《行政处罚法（2021）》第三十三条展开研究，认为本条规定的三个不予行政处罚事由均有各自的法理内涵，应进行分别讨论。其中，无危害性不罚是基于危害性评价而不予行政处罚，首违可以不罚是基于以危害性轻微评价为基础的便宜主义而不予行政处罚，无过错不罚是基于责任主义理论而不予行政处罚。[19]

尽管不少学者对不予行政处罚事由进行了类型化尝试，但往往限于揭示同一类型下不予行政处罚事由的共性，而忽视了类型化研究在不予行政处罚制度整体上的适用意义，以及单个不予行政处罚事由的适用特性。而对于单个不予行政处罚事由的适用研究，往往围绕单个事由展开，而导致整体性研究不足。其中，主要的研究有尹培培在《不予行政处罚论》一文中对“无危害性不罚”的适用探讨，[20]在《论新<行政处罚

[16] 晏山嵘：《行政处罚实务与判例解释》，法律出版社 2019 年版，第 241-251 页。
[17] 熊樟林：《论行政处罚上的违法性阻却事由》，载《行政法学研究》2022 年第 4 期，第 13-26 页。
[18] 周苏湘：《论“不予行政处罚”的逻辑内涵及其适用展开》，载《行政法学研究》2022 年第 2 期，第 56-65 页。
[19] 谢红星：《不予行政处罚的法理——围绕<行政处罚法>第 33 条而展开》，载《广东社会科学》2022 年第 2 期，第 241-251 页。
[20] 尹培培：《不予行政处罚论——基于<我国行政处罚法>第 27 条第 2 款规定之展开》，载《政治与法律》2015 年第

中国知网 https://www.cnki.net

法>中的“主观过错”条款》一文中对“无主观过错不罚”的适用探讨，[21]熊樟林在《论行政处罚上的违法性阻却事由》一文中对于正当防卫、紧急避险、职务行为、行政许可行为等违法性阻却事由的适用探讨，[22]张淑芳在《免罚清单的实证与法理》一文中对免罚清单的适用探讨，[23]张红、岳洋在《行政处罚“首违不罚”制度及其完善》一文中，[24]江国华、丁安然在《“首违不罚”的法理与适用》一文中对“首违可以不罚”这一事由的适用探讨，[25]周优、刘琦在《税务执法“首违不罚”的法理阐释与制度完善》一文中、胡彦伟在《税务领域“首违不罚”制度的若干问题探究》对“首违可以不罚”这一事由在税务执法领域的适用探讨等。[26]。

（二）评述：总结与反思

根据上述不予行政处罚事由的研究现状，可以得出以下结论：

一是，不予行政处罚事由在当下仍呈现扩充的趋势。近年来，随着我国行政法治不断推进，公权力机关对于行政相对人权益的保护更为全面和细致，因此将更多事由纳入了不予行政处罚的范畴。例如，《行政处罚法（2021）》新增了“当事人有证据足以证明无主观过错不罚”条款，推动我国行政处罚立场由客观归责到主观归责转变，提升了行政执法实践中人权保障的水平。与此同时，随着执法水平和执法能力的提升，更为缓和、人性化的执法手段作为行政处罚的替代措施进入公共行政的视野，以期提高行政效能、降低政府管理成本、缓解治理压力。例如，在有些部门行政执法中，出现了以社会服务替代行政处罚的处理方法。

二是，对于不断扩充的不予行政处罚事由，当前并未形成一致的体系化研究思路；对于不予行政处罚事由之适用的研究，主要针对单个事由展开。当前不予行政处罚事由的体系研究主要有以下几种思路：（1）列举分析，即一一罗列不予行政处罚事由。但列举并非真正意义上的类型归纳，且列举是无穷尽的，对于把握不予行政处罚背后的法理、促进行政处罚规范化的意义极为有限。（2）凝练总结不予行政处罚事由的特点，并以其共同特点作为分类依据展开类型化研究。总体而言，这一分类方法对于系

11 期，第 149-160 页。

[21] 尹培培：《论新<行政处罚法>中的“主观过错”条款》，载《经贸法律评论》2021 年第 3 期，第 50-62 页。

[22] 熊樟林：《论行政处罚上的违法阻却事由》，载《行政法学研究》2022 年第 4 期，第 13-26 页。

[23] 张淑芳：《免罚清单的实证与法理》，载《中国法学》2022 年第 2 期，第 243-263 页。

[24] 张红、岳洋：《行政处罚“首违不罚”制度及其完善》，载《经贸法律评论》2021 年第 3 期，第 20-34 页。

[25] 江国华：《“首违不罚”的法理与适用》，载《湖北社会科学》2021 年第 3 期，第 143-153 页。

[26] 周优、刘琦：《税务执法“首违不罚”的法理阐释与制度完善》，载《税务研究》2021 年第 9 期，第 96-101 页；胡彦伟：《税务领域“首违不罚”制度的若干问题探究》，载《税务研究》2021 年第 12 期，第 67-71 页。

中国知网 https://www.cnki.net

统把握不予行政处罚事由的共同特征而言颇有助益。但从不同角度分析，不予行政处罚将具有不同的特点，因此在多元的分析视角下，该分析思路容易产生不同的分类结果，且类型与类型之间缺乏统合的基础、存在难以穷尽的缺点，对于指导行政执法实践的意义较为有限。（3）以行为是否构成违法行为为分类标准，将不予行政处罚事由分为免除违法性的不予行政处罚事由和不免除违法性的不予行政处罚事由。该分析进路揭示了不予行政处罚事由最为本质的属性，即行为是否具有违法性。但该分类过于宽泛，未能高度凝练不同事由在法律评价与实践运用中的共性与区别。因此，这一分类方法就系统把握不予行政处罚事由、指导行政执法实践而言，只能发挥有限的作用。

综上，不予行政处罚事由的体系研究既要避免一一列举的研究方式，又要避免过于宽泛和空洞的类型化解读。在《行政处罚法》确立的行政处罚逻辑框架下，从行政法律责任的产生及实现这一视角考察不予行政处罚事由、对其进行类型化，并对在此基础上对不予行政处罚事由之识别与适用展开探讨，或能够为不予行政处罚实践提供更为有力的理论指引，从而提高行政处罚决定的规范性，更好地保障行政相对人的合法权益。

三、研究的意义与价值

基于实质法治、个案正义、人性化执法等方面的考虑，法律规范创设了对于违反行政管理秩序行为的不予行政处罚事由。存在该事由的，即便当事人之客观行为、行为结果、行为与结果之间的因果关系与行政处罚性法律规范相符，行政机关在个案中仍应当或者得以放弃追究该行为或者对行为人不予行政处罚。在行政执法实践中充分考虑不予行政处罚事由，是保障行政处罚合法性与合理性、推动形式法治走向实质法治的必然要求，更是提高行政执法效率、落实包容审慎监管理念的现实需求。本文旨在通过对行政处罚立法与实践中的不予行政处罚事由进行梳理及类型化，帮助从整体层面认知和把握不予行政处罚事由的范围和适用，以在保护公共利益的同时，充分保护行政相对人的合法权益。

1. 理论层面的意义。一是有助于推动不予行政处罚事由的系统化整理。通过对不予行政处罚事由类似特征的凝练与差异的提取，能够更加直观地、系统性地呈现各不予行政处罚事由之间的差异性特征，实现不予行政处罚事由的体系化。二是有助于构建和完善行政处罚框架体系。通过类型划分，能够简练、系统地囊括各种形式的不予行政处罚事由，有助于夯实行政处罚框架体系的基础，明确罚与不罚背后的法理基础。

中国知网 https://www.cnki.net

三是有助于促进行政法律责任相关理论的完善。国内行政法学界对于行政处罚适用理论模型的探讨，大多限于违法行为或应受行政处罚行为的成立，而对于行政法律责任产生后的实际承担缺乏研究。这容易导致“行政法律责任是否产生”与“行为人是否需要实际承担行政法律责任”的混淆。本文通过对不予行政处罚事由的类型化梳理，对行政处罚这一惩戒性行政法律责任的产生与承担条件及相关内容予以明确，有助于行政法律责任相关理论的完善。

2. 实践层面的意义。尽管《行政处罚法》对不予行政处罚事由进行了较为全面的规定，但由于配套规则的缺位，不予行政处罚制度在实践中的适用并不理想，从而导致颇多行政处罚的合法性与合理性受到质疑。本文对于不予行政处罚事由的法理及其适用进行类型化的系统梳理，一则为各领域行政处罚立法对不予行政处罚事由的细化与完善提供更妥当、有针对性的视角，二则有助于为行政机关之执法活动和法院之司法审查提供明确的指引，并促进行政处罚的规范化。

四、研究的思路与方法

（一）研究的思路

本文的研究内容主要包括不予行政处罚事由的类型化思路、具体类型安排以及各类型不予行政处罚事由的典型情形及适用，所采用的文章结构为总-分结构。具体研究思路为：首先，明确不予行政处罚事由的类型化思路。本文选取行政法律责任的产生与实现这一视角，对不予行政处罚进行类型化。根据行政法律责任的不同状态，不予行政处罚事由可对应地分为违法构成缺失事由、行政法律责任消灭事由、免予行政处罚事由。其次，结合具体的立法、执法、司法案例，分别对违法构成缺失事由、法律责任消灭事由以及免予行政处罚事由的典型情形及适用展开研究。其中，对违法构成缺失事由的研究中，主要对实质违法性缺失之不罚以及因有责性缺失之不罚两类不罚事由展开探讨；对行政法律责任消灭事由的研究中，探讨行政处罚权丧失以及行政处罚对象灭失两类情形；对免予行政处罚事由的研究中，对法定免罚事由以及裁量免罚事由展开探讨。

（二）拟采用的研究方法

1. 规范分析研究方法。任何法律研究都不能脱离法律规范体系本身，本文研究不予行政处罚事由，其落脚点就在于对法律规范中有关对行政相对人不予行政处罚的相

中国知网 https://www.cnki.net

关规定进行梳理、分析。

2. 实证研究方法。实证主义强调研究必须建立在对研究对象进行大量的观察、实验和调查得出的经验事实之上，通过对大量经验事实进行归纳、总结得出的数据以及规律来揭示一般结论。本文将通过收集、分析研究现有的司法判决文书、行政处罚纠纷案件等资料来为本文观点提供有力支撑。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 不予行政处罚事由的类型化价值、逻辑与具体安排

第一节 类型化的价值

不予行政处罚，是指出于特定原因，对违反客观法律规范的行政相对人，不适用行政处罚。这一特定原因即为不予行政处罚的事由。“分类”是法学研究的基本方法之一。通过对不予行政处罚事由进行类型划分，有助于把握不同事由的特点和适用，构建逻辑清晰的行政处罚框架体系，为行政处罚执法活动提供有效指引。

一、不予行政处罚事由类型化的理论价值

类型化是一种合并同类项的研究方法，能够系统化地彰显各种不予行政处罚事由的性质、特征及所能引起的法律效果，进而为不予行政处罚事由描摹出一张体系化的理论图谱，推动行政处罚框架体系的构建和完善。一方面，类型化研究有助于推动不予行政处罚事由的系统化整理。《行政处罚法（2021）》虽然关注到执法实践的发展，新增了“首违不罚”、“无主观过错不罚”、“法律适用从旧兼从轻”等条款，回应了行政处罚制度体系发展的需要。但从立法技术上看，其仅仅是进行不完全列举，而尚未实现类型化归纳与体系化阐释。借助分类的方法，有助于明晰不同事由在特点和适用方面的共性和差异，推动不予行政处罚事由清晰有序的系统化整理。另一方面，不予行政处罚事由的类型化有助于构建和完善行政处罚框架体系。行政违法行为的认定和行政处罚决定的作出，是行政处罚框架体系的关键部分。而不予行政处罚事由作为阻却行政处罚决定作出的事项，同样构成了行政处罚框架体系的重要组成部分。类型化亦是一项重要的整理技术，能够简练、系统地囊括各种形式的不予行政处罚事由，有助于以行政法律责任为核心，明确何以罚、何以不罚，夯实行政处罚框架体系的基础。

二、不予行政处罚事由类型化的实践价值

作为实践性较强的一门学科，行政法学的理论研究与实际运用往往紧密相连。对于不予行政处罚事由进行类型化研究，既是解决行政执法实践中显现的新问题的必然要求，也是回应行政执法实践发展的现实需要。随着我国步入“法治一体建设”阶段，行政权被要求在良法的规范下助成善治，行政机关的角色不再限于做秩序的维护者，还要成为经济和社会发展的促进者。法治建设的时代迁徙，也引发了行政处罚的功能

中国知网 https://www.cnki.net

性变革。行政处罚越来越强调制裁的教育性，而非制裁的严厉性，由此，越来越多的柔性执法方式进入公众视野。“不予行政处罚”便是我国行政处罚功能变迁的见证与表现。然而遗憾的是，在我国审慎立法、渐进式立法的传统之下，新《行政处罚法》并未针对不予行政处罚事由进行体系化建构，导致散见于行政立法、行政惯例之中的各种不予行政处罚事由，在缺乏总则性条款的指引下野蛮生长。此类现象的出现，不仅有损个案正义，同时也对法治统一造成潜在威胁。在此背景下，系统性地归纳、分析、研判不予行政处罚事由，有助于平息实践与地方立法中的不予行政处罚适用乱象，促进行政执法规范化，进而彰显《行政处罚法》作为行政处罚领域立法的总则性地位。

第二节 类型化的逻辑：行政法律责任状态的视角

类型化视角的选择，直接影响到不予行政处罚事由类型的析出。面对复杂多样的不予行政处罚事由，仅仅归纳不同事由的特点或者以违法性有无为标准进行二分，不利于系统把握处于动态发展中的不予行政处罚事由。以行政法律责任状态为视角的类型化分析，契合行政处罚决定的作出逻辑，有助于在行政处罚框架下实现不予行政处罚事由的体系化。在该视角下，根据行政法律责任状态的不同，不予行政处罚事由可以划分为违法构成缺失事由、行政法律责任消灭事由、免予行政处罚事由。

一、对既有类型化思路的辨思

当前，我国学界对于不予行政处罚事由的类型化研究，主要存在两种思路。一是采取列举或者归纳不予行政处罚事由特征的方式进行分类。例如，学者晏山嵘基于不同事由的特点，将不予行政处罚分为四个类型，即“正当化的”、“可赦免的”、“可谅解的”以及“不需罚的”处罚阻却事由。[27]该思路对不予行政处罚事由的个性特征给予了较高的关注，但其对不予行政处罚事由的共同属性关注不足，容易导致类型化的重点从“归纳”转化为“列举”，难以容纳未来可能出现的新事由，偏离不予行政处罚事由分类的目标。二是以“行为是否具有违法性”为分类标准，将行为划分为免除违法性的不予行政处罚事由和不免除违法性的不予行政处罚事由。免除违法性的不予行政处罚事由是指某一行为在客观上或者外形上具备应受行政处罚行为的构成要件，但由于法定原因而免除其违法性，从而对相对人不予行政处罚；不免除违法性的不予行政处罚事由是指某一行为属于一个地地道道的违法行为，但由于其具备某种特定的免予

[27] 晏山嵘：《行政处罚实务与判例解释》，法律出版社 2019 年版，第 241-251 页。

中国知网 https://www.cnki.net

处罚条件，行政机关对其免予处罚，该免予处罚并不能改变行为的性质。[28]这一类型化思路能够揭示行为的本质属性——即违法性之有无，是对不予行政处罚事由共性的高度凝练，但其缺乏对不予行政处罚事由之间个性的关照，导致同类型不予行政处罚事由之间的差异性远多于彼此间的共性。譬如，违法行为逾越追究时效与轻微违法行为二者，尽管皆为不免除行为违法性的不予行政处罚事由，但其在法理考量、行政机关判断空间等方面均存在较大的差异，从而缺乏可以等而视之的共性。

综上所述，不予行政处罚事由的体系研究既要避免列举式的研究方式，又要避免过于宽泛的类型化解读。为使不予行政处罚事由形成体系化，并尽可能地对行政处罚实践有所裨益，对不予行政处罚事由的分类应以行政处罚决定的作出逻辑作为分析的基础和依据。

二、基于行政法律责任状态视角的类型化思考

行政处罚决定的作出和实施，围绕着行政法律责任的产生和实现展开。《行政处罚法》的修订，进一步明确了行政处罚作为惩戒性行政法律责任的实现逻辑。尽管客观违法行为产生后，不予行政处罚事由均指向对行为人不适用行政处罚这一事实结果，但其背后的法律蕴含与适用逻辑，因法律责任状态的不同而存在差异。

首先，惩戒性行政法律责任产生的必要前提是违法行为成立。根据《行政处罚法》第二条，行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的行政相对人予以惩戒的行为。因此，无违法即无处罚。但并非所有违反客观法律规范的行为都构成违法行为。违法行为的成立要件包括形式违法性、实质违法性与有责性要件。这三个部分并非处于平面耦合的结构之中，而是具有递进式的逻辑结构，从事实到价值、从客观到主观依次展开对行为的分析。形式违法性是指特定行为在客观上违反国家法律规范，符合行为、结果、因果关系等客观构成要件，具有客观构成要件该当性；实质违法性指行为在其发生的背景下违背了法律精神、法律原则，由此应受到否定的法律评价；有责性则指该客观不法行为能够归责于当事人。理论上，有责性包括责任能力和责任条件两部分。其中，责任能力主要是指行为人具有对自己行为负责的能力，从而应受行政处罚的制裁，责任条件是指行为人是否具有故意和过失。

其次，惩戒性法律责任的存续是国家机关行使处罚权并将其予以实现的必要条件。违法行为成立后，行政相对人所应承担的法律责任并不一定是行政处罚，除行政处罚

[28] 汪永清：《关于应受行政处罚行为的若干问题》，载《中外法学》1994 年第 2 期，第 24-25 页。

中国知网 https://www.cnki.net

外还存在着单一或者一并承担其他法律责任的可能。[29]只有行政法律规范以处罚性规定要求行政机关对该行为课以一定的行政处罚的，行为人方应承担惩戒性法律责任。同时，惩戒性行政法律责任产生后并非恒久不灭的，与刑事责任相同，除了因实施完毕而归于消灭之外，其可能基于法定或者事实的原因而归于消灭。法律责任一经消灭，国家机关则不得再行使处罚权，要求行为人承担惩戒性法律责任；只有在法律责任存续期间，国家机关方得以、并在原则上应当追究行为人之法律责任。

最后，在惩戒性法律责任的存续期间，国家机关原则上应当追究行为人之法律责任。但由于特殊事由，法律免除或者行政机关经裁量依法免除了当事人法律责任的，行政机关不再对行为人作出行政处罚决定。因此，法定免罚事由、裁量免罚事由的符合性判断是行政处罚决定作出的最后判断。只有行为人之行为不满足法定免罚事由、经裁量应予以行政处罚的，行政机关方能作出行政处罚决定，要求行政相对人承担惩戒性法律责任。

因此，对行政相对人不予行政处罚，相对应地涉及到法律责任的未产生、法律责任的消灭以及法律责任持续期间的免除。根据法律责任状态的不同，可以将不予行政处罚事由具体区分为违法构成缺失事由、行政法律责任消灭事由、免予行政处罚事由。

第三节 类型化的具体安排

根据不同的行政法律责任状态，可以将不予行政处罚事由分为违法构成缺失事由、行政法律责任消灭事由以及免予行政处罚事由。其中，违法构成缺失的事由包括实质违法性缺失事由与有责性缺失的事由；法律责任消灭事由包括处罚权丧失事由与处罚对象灭失事由；免予行政处罚事由包括法定免罚事由与裁量免罚事由。

一、违法构成缺失事由

违法构成缺失的，不能成立违法行为，不产生法律责任。违法行为的构成包括形式违法性、实质违法性与有责性三个部分。因此，违法构成缺失，理论上包括形式违法性缺失、实质违法性缺失与有责性缺失。其中，形式违法性的判断要求将行为人的违法行为、结果、行为与结果之间的因果关系与行政处罚性法律规范进行比对。但缺乏形式违法性的行为由于缺乏秩序侵害性而不纳入行政处罚考虑的范畴，因此本部分主要对实质违法性缺失与有责性缺失这两类事由展开探讨。实质违法性缺失，是指特

[29] 黄锫：《应受行政处罚行为成立要件的法理构造》，载《浙江学刊》2022 年第 2 期，第 47-49 页。

中国知网 https://www.cnki.net

定行为尽管在外观上造成了侵害法益的结果或者带来了侵害法益的危险，但由于特定原因或者情况，在实质上不存在值得保护的法益，从而法律对该行为采取容许乃至认可的态度；或者由于该行为所保护的法益大于其损害的法益，经法益衡量后，法律对于该行为予以认可。当前，行政处罚立法与实践中的实质违法性缺失事由包括正当防卫、紧急避险、法令行为、义务冲突、被害人在权限范围内的承诺等。经判断，形式违法行为不具有实质违法性的，其违法性应予排除，该行为不再具备违法性。有责性缺失，是指根据《行政处罚法》以及相关行政处罚性法律规范的规定，具有客观违法性的行为不能归责于当事人。有责性缺失的原因，一是行政相对人不具备承担行政责任能力的条件；二是行为人在实施不法行为时，不具有行为所要求具备的主观条件。因此，有责性缺失之事由包括责任能力缺失和责任条件缺失两个部分。

二、行政法律责任消灭事由

违法行为成立后，违法行为之行政法律责任便产生了。但经一定期限或者由于特定事由的出现，国家机关对于当事人的行政处罚适用权可能不得再予行使，此即惩戒性行政法律责任之消灭。行政惩戒性法律责任消灭的，行政机关不再对当事人作出行政处罚决定。在一些情况下，行政法律责任因行政机关的处罚权灭失而消灭。一是由于超过时效导致的法律责任消灭。出于敦促行政机关及时行使行政执法权、提高行政执法效率、维护社会秩序的安定性等方面的考虑，《行政处罚法》中规定了行政机关对于违法行为人的追究时效，在该期限内行政机关未予追究的，该法律责任消灭。二是由于新法的出台更改了原法律规定导致的法律责任灭失。根据《行政处罚法》第三十七条，新的法律规定颁布后，原违法行为在新法中不再视为违法或者不再受处罚的，适用新法的规定，行政机关不再对当事人适用行政处罚。此外，特定法律事实出现，导致当事人不具有承担行政法律责任的可能的，行政法律责任也会归于消灭，即处罚对象的灭失。例如，违法行为人死亡的，没有遗产，也没有应当承担义务的人的，其应承担的惩戒性法律责任均不再有被实现的可能的，行政法律责任自然消灭。

三、免予行政处罚事由

在法律责任存续期间，行政机关原则上应当追究违法行为人之法律责任。尽管某些行为构成了违法行为，但在某些特殊情形下，对其仍缺乏以处罚的手段制止违法行为的必要性。对此，一方面，法律规定了对于特定行为的免予处罚事由，违法行为符

中国知网 https://www.cnki.net

合法定免罚事由的，行政机关不得对行为人适用特定行政处罚。当前，法定免罚事由主要包括无危害性不罚和一事不再罚两种情形。另一方面，法律往往赋予行政机关一定的行政裁量空间，使其得根据违法行为情节等因素判断是否免除行政处罚，或者以其他行政手段替代行政处罚，以实现保障个案正义、提高行政效率、鼓励违法行为人改正等目标。当前，裁量免罚的典型事由有“首违可以不罚” 以及其他“附条件可以不罚”，如受害人和解并履行赔偿义务可以不罚、主动参加社会服务可以不罚等。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 违法构成缺失事由

行政违法行为成立是行为人承担法律责任的前提。违法行为的成立条件包括形式违法性、实质违法性与有责性三个部分。特定行为具备形式违法性，但存在实质违法性与有责性缺失情形的，不构成违法行为，对行为人不得作出行政处罚。

第一节 实质违法性缺失之不罚

对于具有形式违法性的行为，实质违法性判断是违法行为认定和行政处罚作出的首要环节。特定行为存在正当防卫、紧急避险、法令行为、义务冲突、被害人承诺等法律允许或认可之情形的，其行为之违法性得到阻却。

一、正当防卫

正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而对不法侵害者实施的制止其不法侵害且未明显超过必要限度的行为。根据我国《刑法》第二十条、《民法典》第一百八十一条，正当防卫造成损害的，不负刑事责任、民事责任。[30]尽管《行政处罚法（2021）》并未明确将正当防卫作为不予行政处罚事由，但公民享有正当防卫权、对正当防卫行为不予行政处罚已经成为普遍共识，并在实践中得到应用。张明楷教授指出：犯罪行为与其他一般违法行为都是侵犯法益的行为，法益都受到法律保护。面对一般违法行为，公民同样可能需要正当防卫以维护合法利益；在紧急情况下，公民甚至难以区分其面对的是一般违法行为抑或是犯罪行为。因此，没有理由禁止公民对一般违法行为进行正当防卫。刑法使用了‘不法’一次，而没有使用“犯罪”概念，表明对其他一般违法行为可以进行防卫。[31]因此，对违法行为进行正当防卫，从而在外观上违反行政法律规范的，不构成违法行为，对行为人应不予行政处罚。这一理念在部分行政法律规范中亦得到贯彻。[32]

[30] 《中华人民共和国刑法》第二十条第一款规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任”；《中华人民共和国民法典》第一百一十八条第一款规定：“因正当防卫造成损害的，不承担民事责任。”

[31] 张明楷著：《刑法学》，法律出版社 2016 年版，第 198 页。

[32] 例如，《公安机关执行<中华人民共和国治安管理处罚法>有关问题的解释（二）》第一条被视为正当防卫在治安管理处罚中的规定，根据该条文，为了免受侵害而采取的制止侵害行为，不属于违反治安管理行为。其第一条规定“一、关于制止违反治安管理行为的法律责任问题：为了免受正在进行的违反治安管理行为的侵害而采取的制止违法侵害行为，不属于违反治安管理行为。但对事先挑拨、故意挑逗他人对自己进行侵害，然后以制止违法侵害为名对他人加以侵害的行为，以及互相斗殴的行为，应当予以治安管理处罚。”

中国知网 https://www.cnki.net

但对于特定行为是否构成正当防卫，在实践中往往出现争议。例如，在“范某某诉安丘市公安局行政处罚案”中，一审法院认为原告不具备正当防卫的主观要件；而二审法院认为，当时存在不法侵害，原告之制止行为应认定为正当防卫。[33]同时，由于判断规则的不明确，出现了对正当防卫认定过严的情形，对公民依法抵抗不法侵害造成了不利影响。例如，在“刘某某诉阜新蒙古族自治县公安局、阜新蒙古族自治县人民政府案”中，原告遭受第三人两人的追打，且在第三人持有工具的情况下，原告的人身、财产安全遭受重大危险。但法院“尽管是王某某（第三人）先动手殴打刘某某（原告），但刘某某有反手回击王某某的行为，该行为不是制止王艳国侵害行为的必须”之认定，显然对于在遭受不法侵害的原告提出了过于严苛的要求，未考虑当时双方力量对比，脱离当时情景作出判断，导致该判断与社会公众之认知脱节。

因此，有必要进一步明确正当防卫在行政处罚中的判断规则，为实践提供更为明确的指引。对于正当防卫的判断规则，行政法学界一致认为可以参照刑法学的相关认识，围绕行为人是否具备防卫意图、防卫起因、防卫对象、防卫时间、防卫限度这五个成立条件展开判断。[34]具备以上五个条件的，行为人的正当防卫成立；否则，不成立正当防卫，行为人违反行政法律规范，对他人造成伤害的，应依法承担行政法律责任。例如，“臧某某诉上海市公安局闵行分局不予行政处罚一案”中，法院认为，原告在与第三人发生争执后，进入涉案房屋厨房内取菜刀并持刀欲对第三人进行伤害，对第三人及其家人的人身安全构成重大威胁，第三人采取强力制止，将原告按压在厨房案板上并迫使原告放弃实施继续侵害行为，在制止过程中对原告肢体造成了轻微伤，既未超出必要的限度，亦未造成重大损害，应认定构成正当防卫。[35]据此，法院认为被告作出不予行政处罚决定认定事实清楚、适用法律正确。本文将结合具体案例，探讨正当防卫在行政法中的适用。

一是防卫起因，即不法侵害的行为实际发生、客观存在。具有制止侵害行为的迫切性、紧急性的，行为人即可进行正当防卫，以保护国家利益、公共利益以及公民、集体的人身、财产权利不受不法侵害；侵害并未客观存在的，对于臆想的或者推测的侵害，行为人不能进行正当防卫。例如，在“金某某与鞍山市公安局铁西分局治安处罚纠纷上诉案”中，法院认为，尽管纠纷双方争吵由原告产生，但第三人的持刀行为

[33] 山东省安丘市初级人民法院行政判决书（2014）安行初字第 22 号；山东省潍坊市中级人民法院行政判决书(2014)潍行终字第 112 号。
[34] 参见熊樟林：《论行政处罚上的违法性阻却事由》，载《行政法学研究》2022 年第 4 期，第 19 页。
[35] 上海市闵行区人民法院行政判决书(2018)沪 0112 行初 51 号。

中国知网 https://www.cnki.net

促使纠纷升级，侵害行为紧急而需要得到制止。为免受持刀伤害，原告可以采取相应行为制止违法侵害。而在案涉行政处罚决定中，行政机关并未查清第三人持刀的事实及该行为对原告造成的影响，作出行政处罚决定的事实不清、证据不足，应予以撤销。[36]而在“张某与青岛市公安局李沧分局治安处罚纠纷上诉案”中，山东省青岛市中级人民法院指出，上诉人张某主张其重要文件材料被第三人窃取而实施正当防卫，殴打第三人并要求第三人返还材料，但上诉人并无证据证明第三人窃取材料。因此上诉人应就材料丢失问题依法向第三人主张权利，其殴打原审第三人的行为不属于免受正在进行违法行为而采取的制止行为，不能成立正当防卫行为。[37]

二是防卫意图，即防卫人对正在进行的不法侵害有防卫认识以及防卫意志。在正当防卫的过程中，行为人必须能够认识到不法侵害正在进行，且出于合法利益免受正在进行的不法侵害的目的而进行正当防卫。对于防卫意图的认定，需避免过于严苛的认定，充分考虑防卫人面临不法侵害时的紧迫状态和紧张心理。一般而言，只要行为人认识到自己的行为是与正在进行的不法侵害相对抗，就应认为具有防卫意识。[38]但行为人构成防卫挑拨、相互斗殴，以侵害对方为意图对对方进行攻击的，应视为不具有制止侵害的目的。例如，在“臧某某诉上海市公安局闵行分局不予行政处罚一案”中，原告持刀欲对第三人进行伤害，对第三人及其家人造成人身侵害的威胁，第三人采取强力制止，应认为其具有防卫意识。在“刘某某、刘某诉宿州市人民政府行政复议案”中，原告刘某某、刘某因生活琐事与孙某相互打斗，双方均有伤害对方的意图，并各自不同程度受伤。双方被小区居民拉开后，双方再次发生厮打，期间，刘某某之子刘某上前持棍状物对孙某进行殴打。二审法院认为，刘某某与孙某是相互斗殴行为，性质上均属于不法侵害，刘某参与其中，并不是为了制止不法侵害和平息事态，而是在斗殴中充当刘某某的帮手，其行为从主、客观两个方面均不符合正当防卫的构成要件，刘某主张其行为属于正当防卫的理由不能成立。[39]

三是防卫对象，即防卫人的行为必须针对不法侵害人进行。其中，多人共同实施不法侵害的，防卫人可以针对直接实施者或者现场共同实施人进行防卫；无或者限制行为能力人实施侵害的，应当尽量躲避或者制止，无法以其他方式躲避或者制止的方

[36] 辽宁省鞍山市中级人民法院行政判决书(2020)辽 03 行终 26 号。
[37] 山东省青岛市中级人民法院行政判决书(2020)鲁 02 行终 443 号。
[38] 张明楷著：《刑法学》，法律出版社 2016 年版，第 198 页。
[39] 安徽省高级人民法院行政判决书(2021)皖行终 222 号。

中国知网 https://www.cnki.net

可以进行反击。[40]例如，在“张某某诉井陉县公安局、石家庄市公安局公安行政管理案”中，法院指出，原告张某某与第三人王某甲发生口角后，闯进柜台与王某甲发生斗殴行为，并在第三人王某乙、王某丙阻挡的过程中对二人实施了伤害。由于王某乙、王某丙并非不法侵害人，其对王某乙、王某丙二人实施的伤害行为不符合正当防卫的防卫对象之要件，因此原告主张其行为属于正当防卫的理由不能成立。[41]

四是防卫时间，即正当防卫必须实施于不法侵害已经开始并且尚未结束的进行阶段，而不允许事先防卫与事后防卫。在“张某某与济南市公安局市中区分局等治安行政处罚上诉案”中，原告张某某诉称其伤害第三人是被迫实施正当防卫。但法院认为，根据本案证据，在原告与第三人之丈夫争执的过程中，第三人之丈夫手拿马扎、原告手持砖头进行对峙，但双方并未产生肢体冲突，第三人对原告之劝阻行为也并未构成不法侵害，原告所受到的威胁并非十分明显、紧迫，因此原告的正当防卫条件并未成就，其行为属于正当防卫的主张不能成立。[42]在“杨某某与民乐县公安局治安行政处罚案”中，再审法院认为，原告与第三人发生纠纷，第三人虽有谩骂行为，但第三人并未对原告实施违法侵害行为，因此原告制止第三人的违法侵害行为并不具备起因条件和时间条件，原告将具有腐蚀性的液体泼向第三人造成第三人轻微伤害，不构成正当防卫。[43]在“姚某某诉广东省封开县公安局、肇庆市公安局治安管理行政处罚案”中，法院认为，在第三人对原告采取侵害行为但迅速被阻隔开的情况下，第三人已不能继续对原告进行侵害，原告仍然拿凳子砸向第三人并造成第三人轻微伤，不构成正当防卫。[44]

五是防卫限度。对于违法行为，行为人的正当防卫不能明显超过必要限度且对不法侵害人造成重大损害。“防卫是否‘明显超过必要限度’，应当综合不罚侵害的性质、手段、强度、危害程度和防卫的时机、手段、强度、损害后果等情节，考虑双方力量对比，立足防卫人防卫时所处情境，结合社会公众的一般认知作出判断。在判断不法侵害的危害程度时，不仅要考虑已经造成的损害，还要考虑造成进一步损害的紧迫危

[40]《最高人民法院最高人民检察院公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见》第七条规定：“准确把握正当防卫的对象条件。正当防卫必须针对不法侵害人进行。对于多人共同实施不法侵害的，既可以针对直接实施不法侵害的人进行防卫，也可以针对在现场共同实施不法侵害的人进行防卫。明知侵害人是无刑事责任能力人或者限制刑事责任能力人的，应当尽量使用其他方式避免或者制止侵害；没有其他方式可以避免、制止不法侵害，或者不法侵害严重危及人身安全的，可以进行反击。”

[41] 河北省石家庄市中级人民法院行政判决书(2020)冀 01 行终 416 号。

[42] 山东省济南市中级人民法院行政判决书(2014)济行终字第 138 号。

[43] 甘肃省高级人民法院行政裁定书(2018)甘行申 220 号。

[44] 广东省肇庆市鼎湖区人民法院行政判决书(2020)粤 1203 行初 107 号。

中国知网 https://www.cnki.net

险性和现实可能性。不应当苛求防卫人必须采取与不法侵害基本相当的反击方式和强度。通过综合考量，对于防卫行为与不法侵害相差悬殊、明显过激的，应当认定防卫明显超过必要限度。”[45]例如，在“崔某某等与新乡市公安局卫东分局、新乡市公安局治安行政处罚及行政复议纠纷再审案”中，法院认为，在本次殴打行为之前双方已发生数次纠纷事件，而案发日第三人崔某某等人在小区内抓住原告实施殴打行为，原告用类似手机的物品击打第三人面部，属于为了免受正在进行的违法侵害而采取的制止违法侵害行为，宜认定为正当防卫，且未超过必要限度。[46]

二、紧急避险

紧急避险是指为了使自己或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的紧急避险行为，该避险行为在外观上造成了侵害另一法益的结果或者带来了侵害危险。与正当防卫相类似，尽管《行政处罚法》并未将紧急避险作为不予行政处罚事由，其在实践中亦得到普遍承认。但不同于正当防卫通过抵抗不法来保护合法权益，紧急避险通过损害一种法益的方法来保护另一种合法权益，因此相比正当防卫，其成立条件更为严格。学者认为，紧急避险的判断大体上也可以参考刑法理论。[47]行为人之行为具有避险起因、避险意图，符合避险时间、避险对象、避险限制要求的，紧急避险行为成立，其不再构成行政违法行为；否则，紧急避险行为不成立。

就避险起因和避险时间而言，合法权益遭受到损害的危险时，且该危险必须正在发生或者迫在眉睫的，行为人才能够实施紧急避险，危险的来源包括自然的力量、动物的侵袭、人的生理、病理过程以及非法侵害行为等。[48]一方面，该合法权益必须是个人法益，且危险必须是客观现实的存在，而不是行为人假想的、推测的存在。例如，在“***诉吉林市公安局交通管理支队直属大队行政处罚案”中，原告因在人行横道前未停车避让行人而被处以行政处罚。原告对此不服，主张涉案路段是冰层路面，由于其车速较快，刹车必造成交通事故，且仍会对行人造成人身安全风险，因此其行为属于紧急避险。法院经审理认为，原告发生违法行为时地面标线清晰可辨，不能证明路面冰雪覆盖程度足以使原告采取紧急避险行为，因此其不避让行为不属于紧急避险情形。[49]另一方面，在危险并不紧迫、直接的情况下，行为人本能够预见并避险危险，但

[45] 参见《最高人民法院最高人民检察院公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见》第十二条。
[46] 河南省高级人民法院行政裁定书(2020)豫行申 262 号。
[47] 熊樟林：《论行政处罚上的违法性阻却事由》，载《行政法学研究》2022 年第 4 期，第 20 页。
[48] 高铭暄：《刑法学》，北京大学出版社、高等教育出版社 2019 年版，第 134 页。
[49] 吉林铁路运输法院行政判决书(2020)吉 7102 行初 88 号。

中国知网 https://www.cnki.net

行为人的故意行为引起紧迫危险发生的，不再构成紧急避险行为。在“蓝某某诉揭阳市公安局交通警察支队高速公路二大队案”中，因原告违反道路交通安全法的规定将车停靠在应急车道上，被告对原告作出行政处罚决定。原告主张其因驾车途中感觉疲劳，为保障行车安全将车停靠在应急车道上进行休息，其行为属于“紧急情况”，因此其停车行为具有正当性，不应受行政处罚。对此，法院认为，机动车驾驶人在驾驶途中的疲劳并不具有突发性和紧急性，而是一个循序渐进的过程，驾驶人能够提前预判并采取正当措施避险，因此不能以实施妨害道路交通安全行为作为其避险的正当理由。[50]

就避险意图而言，行为人必须对正在发生的危险有明确的认识，并且希望通过避险手段来保护较大的合法权益，否则应认为行为人不具备避险意图。例如，在“朱某某诉上海市公安局普陀分局交通警察支队、上海市普陀区人民政府行政处罚决定及行政复议决定案”中，被告上海市公安局普陀分局交通警察支队因原告实施机动车违反规定使用公交专用车道的行为，对原告作出行政处罚。原告主张为避让前车变道驶入公交专用道路，其行为应构成紧急避险行为而不受行政处罚。对此，二审法院指出，上诉人在避让前车后，为超越前车仍继续占用公交专用车道，并加速从前车右侧实施超车，之后才变道驶回其原先所在的车道，因此其连续占用公交道路的行为并非处于为了避免正在发生的危险，亦非突遇前车的正确处理方式，上诉人因其紧急避险可予以免责的理由不能够成立。[51]

就避险对象而言，紧急避险针对的是第三者的合法权益。在实践中，有部分法院将“避险对象”与“防卫对象”相混淆，从而导致正当防卫、紧急避险的混淆。例如，在“孙某某诉高密市公安局行政处罚案”中，法院认为，尽管第三人杜某某拆除原告家门口护栏的行为，造成了一定的危险，但该危险并不紧迫，原告可以采取多种方法避免危险，因此原告采取将第三人杜某某推至湾底这一行为不具有紧急避险的正当性。在本案中，第三人杜某某对原告造成一定危险，原告意图通过制止原告的方式避免危险扩大，应考虑是否构成正当防卫行为，而非紧急避险行为。由于本案中第三人产生的侵害行为并不具有通过正当防卫行为予以制止的迫切性、紧急性，不符合正当防卫的起因条件，因此行为人的行为同样不构成正当防卫。[52]

[50] 广东省揭阳市中级人民法院行政判决书(2021)粤 52 行终 14 号。
[51] 上海市第三中级人民法院行政判决书 （2017）沪 03 行终 856 号。
[52] 山东省高密市人民法院行政判决书(2019)鲁 0785 行初 123 号。

中国知网 https://www.cnki.net

就避险限度而言，紧急避险不能超过必要的限度，造成不应有的损害。紧急避险的本质特征，是为了保护较大的法益，而将该法益所面临的危险转移给较小的法益，因此，紧急避险所损害的法益，必须小于行为人所保护的法益，且未造成不应有的损害。这一点在《德国违反秩序法》得到明确规定。[53]对于法益大小的比较，张明楷教授指出，大体上可以肯定，人身法益重于财产法益，生命法益重于身体法益，但现在还难以形成一般的、具体的标准，只能根据社会的一般观念进行客观的、合理的分析；进行法益衡量时，还要考虑危险的紧迫性与重大性、危险源的具体情况、损害行为的程度、当事人的忍受义务等。[54]行政处罚中对于避险限度的认定，可以参考适用这一判断规则。例如，在“张某某诉平湖市公安局交通警察大队、平湖市人民政府行政处罚及行政复议案”中，原告张某某对于前方车辆突然变向、右侧大型集装箱货车正在转弯而产生的危险，可以采取减速或者停车避让的方式避免交通事故的发生，但原告选择“借道”逆向行使并超车的方式，增加了危险，不符合紧急避险的限度条件。[55]

就避险限制而言，紧急避险只能在不得已的情况下才能实施。这意味着行为人只有在没有其他方法（包括逃避、报警求援、寻求他人帮助或者以正当防卫对抗不法侵害者）排除危险的情况下，才允许选择损害其他合法权益的方法保护该法益。如果当时尚有其他方法可以避免危险，那么其行为不能认定为紧急避险，而应当依法追究其法律责任。例如，在“攀枝花市公安局东区分局对张某某非法侵入他人住宅的行政处罚案”中，张某某于某小区内为一住户安装阳台雨棚，在开始安装雨棚后不久，就发现其在雨棚安装完毕后自己将无法安全返回地面。于是其通过小区物业公司与楼上的住户谭某某进行沟通，希望从其家中借道离开。谭某某表示该时间段家中无人，不同意张某某借道通行。张某某在明知谭某不同意的情况下，仍继续施工，并在施工结束后强行拉开谭某某家的窗户进入谭某某家中并借道离开。对此，攀枝花市公安局东区分局对其处以行政处罚。在陈述申辩的过程，张某主张其翻墙进入他人住宅中是为了紧急避险，不应受到行政处罚。公安机关指出，本案中张某某在实施高空作业之前和高空作业这两个时间段，均可以积极主动地采取其他有效措施来消除自身的安全隐患，但张某某却采取非法侵入他人住宅的违法行为这一做法，违背了法律设定紧急避险的

[53] 《德国违反秩序法》第十六条规定：“紧急避险：为制止正在进行的、无法通过其他方法制止的威胁自己或他人生命、健康、身体、自由、名誉、财产或其他权益的危险而作出的行为，若相冲突的法益即所涉及的权益和遭受危险的程度相较，被保护利益的重要程度明显超出因避险行为而损害的法益，该行为不属于违法行为。本规定仅限于避险行为手段适当时适用。”——熊樟林编：《中外行政处罚法汇编》，北京大学出版社 2021 年版，第 105 页。

[54] 张明楷著：《刑法学》，法律出版社 2016 年版，第 221 页。

[55] 浙江省平湖市人民法院行政判决书(2015)嘉平行初字第 17 号。

中国知网 https://www.cnki.net

立法目的，因此其行为不能认定为紧急避险。[56]

三、法令行为

法令行为，是指基于成文法律、法规、规章的规定，作为权利行使或者义务承担所实施的行为。[57]部分国家和地区的行政处罚中明确规定了法令行为不予行政处罚。[58]我国《行政处罚法》并未明确规定对法令行为不予行政处罚，但法令行为尽管在外观上与某些行政违法行为高度相似，但由于其是法律所允许乃至鼓励的行为，因此应将其作为阻却实质违法性的事由。法令行为包括以下类型。

一是正当职务行为。其一是根据法律的规定直接实施的行为。例如，根据《警察法》第八条，对于严重危害社会治安秩序或者危害公共安全的人员，人民警察可以采取强行带离现场、依法予以拘留的措施。因此，人民警察依法拘留违法人员的，不属于《治安管理处罚法》中规定的“非法限制他人人身自由”，而应属于正当职务行为。其二是公务员根据上级的职务命令实施的行为。根据我国《公务员法》，公务员应当服从和执行上级依法作出的决定和命令，按照规定的权限和程序履行职责。[59]因此，公务员执行上级依法作出的决定和命令的行为，为法律所允许，能够阻却其实质违法性。同时，根据本条，对于上级违法作出的决定和命令，公务员不具有遵循的义务。因此，公务员根据上级的非法决定，实施了违法行为的，不能够阻却其行为的违法性。我国台湾地区的“行政罚法”中也存在对这一类行为不罚的规定，根据其第十一条第二项，依照上级公务员的职务命令作出的行为，除明知职务命令违法而未依程序向上级陈述意见以外的职务命令行为，不受行政处罚。[60]

二是行政机关之许可行为、行政委托行为。符合行政处罚客观构成要件的行为，但经有权行政机关之许可或者委托而得以正当化的，不具有实质违法性。应注意的是，该许可或者委托应经法律法规授权或者允许。“必须行政机关享有权限，对于处罚规定所保护之公共利益得为处分者为限；且必须依‘法律’规定有此种许可或者核准之可

[56] 攀枝花市公安局：“攀枝花市 2019 年度行政处罚十大指导案例之一：攀枝花市公安局东区分局对张某某非法侵入他人住宅的行政处罚案”，攀枝花市司法局官网，http://sfj.panzhihua.gov.cn/qmyfzs/yasf/1857876.shtml，最后访问时间 2022 年 9 月 21 日。

[57] 参见张明楷著：《刑法学》，法律出版社 2016 年版，第 198 页。

[58] 如奥地利《行政罚法》第 6 条规定：“由紧急状态免责的行为，或者虽然符合行政违法行为之事实构成，但系由法律所要求或者允许的行为，不罚。”

[59] 《公务员法》第十四条规定：“公务员应当履行下列义务：（四）忠于职守，勤勉尽责，服从和执行上级依法作出的决定和命令，按照规定的权限和程序履行职责，努力提高工作质量和效率。”

[60] 我国台湾地区“行政罚法”第十一条第二项规定：“依所属上级公务员职务命令之行为，不予处罚。但明知职务命令违‘法’，而未依程序向上级公务员陈述意见者，不在此限。”

中国知网 https://www.cnki.net

能性。”[61]但并非所有行政许可均是违法阻却事由。如果某种行为不具有侵益性，但法律出于预防的目的，对于未经许可的行为一概处罚，经过许可的行为即为合法行为的，许可本身构成了行为合法的构成要件，而非处罚阻却事由。例如，根据《食品安全法》，我国对食品经营实行许可制度，对于未经许可从事食品生产经营活动的行为人，应依法予以处罚。许可成为经营食品的合法要件、食品经营许可处罚的消极要件，行为取得许可时，该行为不再符合违法行为的客观构成要件，而不具有形式违法性，无需上升到实质违法性层面讨论，因此其并非违法阻却事由。作为阻却实质违法事由的行政许可是指对于某种侵益性行为，法律对其予以禁止，同时保留了许可解除禁止的情形，有权行政机关可以在对公共利益进行考量时，在个别案件中例外许可该行为。例如，法律禁止在道路上摆设摊位，但法律另设了某些例外准许在道路摆设摊位的要件的、准予行政机关作出许可的，则行政机关对于行为人的许可，能够阻却其在道路上摆设摊位的违法性。[62]

三是法律、法规明示了合法性条件的行为。即某类行为本来属于违法行为，但法律特别规定，符合一定条件时属于合法行为，不再对行为人予以行政处罚。例如，根据《珠海市经济特区道路交通安全管理条例》第七十二条第二款规定：“因避让执行紧急任务的警车、消防车、消防车、工程救险车而被交通技术监控设备记录或者录入道路交通违法信息管理系统的，应当予以消除，并免予行政处罚。”

四、义务冲突

在义务冲突，亦即在数个彼此冲突的行政法上义务同时存在的情形，应优先履行具有较高的价值之义务，同时以不履行较低价值义务作为牺牲代价，而不构成违法行为。[63]其中，履行义务的行为可以是作为的形式或者不作为的形式。由于同样存在需要进行法益衡量的情形，义务冲突与紧急避险具有一定的相似性。其区别在于，紧急避险中的“避险行为”往往并非当事人需要履行的义务，而仅是其在法益衡量下作出的损害较小法益的选择；而义务冲突情形下当事人根据法律的要求有作出特定行为保护对应法益的义务，但由于客观情况不得不放弃履行其一或者多个义务。但就法益衡量而言，义务冲突之法益衡量可以参考紧急避险下的法益衡量规则，即行为人在义务冲突之情形下，需进行充分的衡量，考虑履行其中某一义务所要保护的法益、不履行另

[61] 陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 110 页。
[62] 参见陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 110 页。
[63] 陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 118 页。

中国知网 https://www.cnki.net

一项义务所导致的危险或者损害程度，并对其进行利益衡量。若行为人履行义务所保护的法益大于未履行其他义务所损害的法益，该行为为法律原则、法律精神所认可，则该行为可阻却实质违法。

但是，如果义务冲突由负有义务的人造成，则不能将义务作为违法性阻却事由。例如，根据《道路交通安全法》等法律法规，机动车驾驶人应遵循交通规则，在规定的车道行使，同时经过没有交通信号的道路时避让行人。而汽车驾驶人甲由于超速行使，在发现行人横过马路时，已经来不及停车避让，于是其选择跨到对向车道行驶以避让行人。此时尽管甲违反道路交通安全法规系由义务冲突引起，但因为该义务冲突是由甲之超速行使行为造成，其义务冲突不能成为其跨车道行使的违法阻却事由。这一观点在行政处罚的执法及司法实践中也得到体现。例如，在“北京某水务有限公司诉北京市怀柔区卫生健康委员会行政处罚及北京市怀柔区人民政府行政复议一案”中，原告北京某水务有限公司因未按规定取得《卫生许可证》从事供水而受到行政处罚。原告辩称其未取得许可从事供水，是由于许可超期未能够及时续办，而其在实际情况下有继续提供生活用水的义务，否则居民生活用水得不到保障，因此其继续供水行为是出于义务冲突下的利益衡量，具有正当性。但由于许可超期未续办是由原告所造成的，行政机关及司法机关均未认可该申辩意见。[64]

五、被害人的承诺

在刑法上一般承认在特定条件下经被害人同意可以阻却违法，其理论基础是被害人的自主决定权。对于公民有权处分的个人法益，公民得通过承诺的方式予以放弃，由此，对导致其无法实现法益的加害者，无需运用法律加以惩戒。“举重以明轻”，理论上，这一违法性阻却事由在行政处罚上同样具有适用空间。但由于行政处罚性法律规范所保护的对象通常是公共利益，或是公共利益与个人利益兼有，而少有个人有权处分的法益，因此被害人承诺在行政处罚上的适用范围较为狭窄。熊樟林教授认为，被害人承诺构成违法阻却事由，必须满足以下条件：一是必须是个人法益，对于超个人的公共利益，承诺不能阻却违法；二是被侵害人对于该法益必须具有处分权；三是被侵害人之意思表示不存在瑕疵，即其并非因受到被恐吓、胁迫而作出非自由的意思表示，也并非基于欺诈、违反法律规范等意思表示而作出承诺。[65]由此，被害人承诺的

[64] 北京市第三中级人民法院行政判决书(2020)京 03 行终 209 号。
[65] 熊樟林：《论行政处罚上的违法阻却事由》，载《行政法学研究》2022 年第 4 期，第 25 页。

中国知网 https://www.cnki.net

范围限于自己可以支配和处分的个人法益，同时不得侵害社会法益和国家法益。通常认为，个人对于其生命权和身体重伤无权承诺；对于身体健康权的承诺，不得违背法律的规定和公序良俗。而对于个人的自由权、人格权和财产权法益，个人一般可以承诺，但该承诺不得构成侵害公共利益的行为，或者导致侵害公共利益的结果。被害人承诺能够构成违法阻却事由的，其行为因不具有实质违法性而不构成违法行为。例如，经过权利人同意，行为人损毁其私人财物，则其行为之实质违法性被阻却了，行政机关不得根据《治安管理处罚法》第四十九条对其作出行政处罚。[66]这是由于权利人主动放弃了其财产法益，法律无需再对其加以保护。

此外，推定的被侵害人承诺同样阻却违法。[67]推定承诺是指虽然权利人因不知情而未作出承诺，但经合理评估其利益状态，能够推定权利人如果知情将会承诺；权利人事后追认与否，不影响该违法阻却事由成立。例如，在权利人之住宅着火但屋中无人的情况下，可以推定其同意他人进入救火。

综上，行为人因正当防卫、紧急避险、法定行为、义务冲突、被害人承诺等事由实施了具有形式违法性之行为的，由于其行为不具有实质违法性而不构成违法行为。判断是否特定行为是否具有实质违法性，其核心在于该行为是否得到法律容忍或者认可。除本章所讨论之情形外，仍可能有部分具有形式违法性之行为经法益衡量或者由于不存在值得保护的法益得到法律认可。

第二节 有责性缺失之不罚

“行为只有作为意志的过错才能归责于我。”[68]法律责任的产生和归结，要求行为人具有认识和判断其行为的能力，以及控制其行为发展的能力。因此，即便特定行为符合违法行为客观要件，具有形式违法性与实质违法性，仍需进一步探求行为人对于该行为是否有责。行为人责任能力缺失、责任条件缺失的，该行为之因有责性之阻却而不构成违法行为，对行为人不得作出行政处罚。

一、责任能力缺失

行政处罚上所称的责任能力，与刑法并无不同，主要是指行为人受行政处罚之制

[66] 《行政处罚法》第四十九条：“盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。”

[67] 陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 121 页；熊樟林：《论行政处罚上的违法阻却事由》，载《行政法学研究》2022 年第 4 期，第 25 页。

[68] [德]黑格尔：《法哲学原理》，范扬，张全泰译，商务印书馆 1961 年版，第 119 页。

中国知网 https://www.cnki.net

裁，必须要以具有对自己行为负责的能力为前提。[69]行为人有能力认识并判断其行为之价值，对自己的行为能够加以控制，仍作出违法行为的，即应对该行为负责，受到否定的法律评价并承担相应的行政处罚。

对于行为人的责任能力的判断，主要有两种判断标准。一是通过责任年龄进行判断。所谓责任年龄，是指法律规定行为人对自己的违法行为负法律责任必须达到的年龄。[70]通常认为，只有达到法定责任年龄，行为人才具有认识并判断自己的行为，并自觉地对自己的行为加以控制的能力；未达法定年龄的，由于其心理、生理并不成熟，辨别是非善恶的能力不足，推定其不具有对自己的违法行为负责的能力。根据《行政处罚法》第三十条，未满十四周岁的未成年人为无责任能力者，对其违反行政法义务的行为不予行政处罚。学者曹康泰指出，对于未成年人年龄的计算应把握以下要点：一是以实足年龄计算，即参照《刑法》相关规定，以日为计算标准，只有过了十四周岁生日，从第二天开始，才能认为行为人已满十四周岁；二是应以未成年人实施违法行为时的时间计算，而非以行政处罚决定作出时的时间计算；未成年人在相邻接的责任年龄期限内，实施了几个违法行为或者持续实施了违法行为的，其只应对达到责任年龄阶段的违法行为负责。[71]

二是通过精神状态进行判断。对于达到法定责任年龄的人，由于其知识与能力得到发展，一般认为其具备认识和控制个人行为的能力，从而认为其具有责任能力。然而，行为人如果由于精神障碍或者心智缺陷等，不具有认识和控制自己行为能力，从而作出违法行为的，应认为其在行为时不具有责任能力而对其不予行政处罚。根据《行政处罚法》第三十一条，《行政处罚法》采取了与刑法一致的判断标准，即丧失辨认能力和控制能力的择一说。[72]经法定程序鉴定，行为人在行为时不具有辨认能力或者控制能力的，则违法构成缺失，对行为人应不予行政处罚。

二、责任条件缺失

责任条件主要指行为是否具有故意或者过失的主观状态。《行政处罚法（2021）》的修订，明确了将责任条件纳入违法行为的构成当中。除法律、法规另有规定外，经

[69] 洪家殷：《行政罚法论》，五南图书出版公司 2006 年版，第 211 页。
[70] 曹康泰：《行政处罚法教程》，中国法制出版社 2011 年版，第 91 页。
[71] 曹康泰：《行政处罚法教程》，中国法制出版社 2011 年版，第 92 页。
[72] 《行政处罚法》第三十一条规定：“精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制行为时有违法行为的，不予行政处罚。间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。”

中国知网 https://www.cnki.net

行政机关查明或行为人有证据足以证明没有主观过错的，对行为人不予行政处罚。据此，责任条件缺失将导致有责性缺失，其应作为违法构成缺失的事由之一，纳入到不予行政处罚事由当中。因而，有必要进一步明确责任条件缺失的情形，以及其在不予行政处罚中的具体适用。

（一）违法构成中的责任条件

在 2021 年《行政处罚法》修订前，对于责任条件是否构成违法行为的构成要件存在较大争议。一种观点认为，行政处罚应采取过错原则，即只有行为人主观上存在过错，方能够对其作出行政处罚，主观上无过错的行为人不受行政处罚。[73]另一种观点认为，主观过错并不是违法行为的构成要件，根据现行行政处罚性法律规范，在多数情况下，只要行为人存在客观违法行为，就要对行为人加以处罚。在此情形下，行政机关无需探求行为人的主观状态。[74]第三种观点认为，行政处罚采用过错原则，但以过错推定的方式适用，即只要行为人存在违反法定义务的事实的，处罚机关就可以推定行为人具有过错存在，只有在行为人证明其不具有过错的情况下，才能免除其法律责任。[75]

现行行政处罚性法律规范关于违法行为人的主观状态，通常存在以下几种情况的规定。其一，在部分情况下，明确相对人实施违法行为具有主观故意，才能给予行政处罚。例如，根据《治安管理处罚法》第二十五条第一项规定，对于散布谣言等扰乱公共秩序的行为，只有出于故意的，才能对行为人作出行政处罚。[76]其二，在极少数情况下，明确相对人实施违法行为，具有过失的，才能给予行政处罚，该过失通常以管理过失的形式呈现。例如，根据《海上交通安全法》第一百零二条第二款规定，引航机构派遣引航员存在过失，造成船舶损失的，由海事管理机构对引航机构实施行政处罚。[77]其三，多数情况下，只要行为人实施了违反行政管理秩序的行为，即应当予以处罚，而不苛求主观要件。[78]例如，根据《水污染防治法》第八十九条第二款，船舶进行

[73] 参见姜明安：《行政违法与行政处罚》，《中国法学》1992 年第 6 期，第 42 页；应松年主编：《行政行为法》，人民出版社 1993 年版，第 473 页。
[74] 参见孙秋楠：《受行政处罚行为的构成要件》，《中国法学》1992 年第 6 期，第 47 页。
[75] 参见江必新：《论应受行政处罚行为的构成要件》，《法律适用》1996 年第 6 期，第 4 页。
[76] 《治安管理处罚法》第二十五条第一项规定：“有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：（一）散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的。”
[77] 《海上交通安全法》第一百零二条第二款规定：“引航机构派遣引航员存在过失，造成船舶损失的，由海事管理机构对引航机构处三万元以上三十万元以下的罚款。”
[78] 参见马怀德《<行政处罚法>修改中的几个争议问题》，载《华东政法大学学报》2020 年第 4 期，第 10 页。

中国知网 https://www.cnki.net

涉及污染物排放的作业，未遵守操作规程或者未在相应的记录簿上如实记载的，由有权机关责令改正，并对其处以罚款。[79]在对此类违法行为进行行政处罚的过程中，国家机关往往不以责任要件作为其违法构成条件，或者说并不探求行为人就客观违法事实是否具有主观过错。但“行为只有作为意志的过错才能归责于我”，[80]这一实践思路由于违背了基本的法理与情理，对人的自由意志尊重不足，长期受到理论的批评。

新《行政处罚法》第三十三条第二款的规定打破了以上模式，将主观过错纳入行政处罚的考量过程。[81]换言之，当事人的主观状态作为责任要件纳入违法构成当中。其中，行政处罚性法律规范对违法行为明确要求故意、过失的，行政机关承担该构成要件的证明责任，只有充分证明行为人具有相应故意和过失，才能对行为人作出行政处罚，否则不得作出行政处罚。法律规范对违法行为未规定故意、过失的，推定行为人具有过错，行为人有证据证明其不具有主观过错，过错推定被推翻的，行政机关也不得作出行政处罚。

（二）行政机关承担过错举证责任的情形

由于行为人的主观意识往往外化于行为，因此，行政机关进行违法认定时，得通过收集证据，根据行为人的外在行为推定其是否具有主观过错以及属于何种主观意识。同时，根据《行政处罚法》主观过错条款，行政机关的这一推定，可以由当事人相反的证据推翻。在此情形下，根据行政机关所收集之证据不能认定或者推定行为人具有特定主观过错的，应认为行为人不具有相应主观过错，从而应对其不予行政处罚。例如，根据《治安管理处罚法》第四十九条，当事人的故意是该应受行政处罚行为的成立要件，若当事人对于财物的损毁并无故意，则该行为不成为应受行政处罚行为，从而当事人无需受到行政处罚。[82]因此，除了当事人的行为造成财物毁损的证据，行政机关仍需进一步提出足以推定当事人具有主观故意的证据，而非根据财物毁损这一行为结果，直接推定当事人具有主观故意。由行政机关所收集的证据无法合理推定当事人具有主观故意的，不得对当事人进行行政处罚；由行政机关所收集的证据能够合理推

[79] 《水污染防治法》第八十九条第二款规定：“船舶进行涉及污染物排放的作业，未遵守操作规程或者未在相应的记录簿上如实记载的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款。”

[80] [德]黑格尔：《法哲学原理》，范扬，张全泰译，商务印书馆 1961 年版，第 119 页。

[81] 金成波：《行政处罚中违法者主观认识论纲》，《当代法学》2022 年第 4 期，第 105 页。

[82] 《行政处罚法》第四十九条规定：“盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。”

中国知网 https://www.cnki.net

定当事人具有主观故意的，应进一步听取当事人的陈述申辩，若当事人有证据足以证明自己确无主观过错的，应受行政处罚行为不成立，同样不得作出行政处罚。

就故意而言，故意包含构成要件实现之认识与意欲两个因素，其在以下情况下成立：一是认识全部的客观构成故意的成立要素，包括对于构成法律规定的前提要件特征有认识，或是对于将进行的行为经过之后，将发生满足发生构成要件事实，有所预见；二是意欲并积极追求实现构成要件（直接故意），或者放任构成要件事实的发生（间接故意）。[83]例如，根据《治安管理处罚法》第四十二条，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，对行为人处以行政处罚。其中，“公然侮辱”与“捏造事实诽谤”都抱着对极强的主观故意意志的要求，即行为人对于侮辱他人与诽谤他人而产生的结果是积极追求并迫切希望结果发生的。在“杨某某诉浙江省杭州市公安局公共信息网络安全监察分局不予行政处罚决定纠纷案”中，杭州市上城区人民法院指出，违法行为人在网络上捏造事实并散布虚假事实，其明知“素怀”这一网民具有现实性和特定性，也明确知道自己散布的事实在客观上足以导致他人名誉受损，仍积极实施该行为并追求这一结果，属于故意，因此应对其捏造事实损毁他人名誉的行为予以行政处罚。[84]

相反，若根据案件事实，不能直接认定或者推定行为具有实现构成要件及其结果的认识与意欲因素的，应认为其行为不具有主观故意，违法行为的责任要件缺失。例如，根据《治安管理处罚法》第四十九条，对于损毁公私财物的行为给予行政处罚，应以故意为限。在最高人民检察院作为 2021 年度行政检察典型案例发布的“毛某诉河南省某市公安局、市政府行政处罚及行政复议监督案”中，毛某作为钩机车司机，在政府主导的项目施工过程中，将郑某房屋设施推倒损坏。经郑某报案后，市公安局以故意损坏财物为由，对毛某作出行政拘留的处罚决定。毛某申请复议被维持后，毛某提起诉讼，经一审、二审、再审均未获支持。毛某向检察机关申请监督，河南省检察院依法受理并经事实查明后认为，毛某虽然客观上实施了拆除行为，但公安机关提供的证据不能证明其具有损毁公私财物的主观故意，因此当事人故意损毁财物的违法行为不能成立。河南省检察院据此向省高院提出抗诉，河南省高院采纳了这一抗诉意见并依法作出改判，撤销了案涉行政处罚决定以及行政复议决定。[85]

就过失而言，就过失而言，过失是指行为人虽非出于故意，但按照情节，应当注

[83] 参见陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 134-135 页。
[84] 浙江省杭州市上城区人民法院行政判决书(2008)上行初字第 6 号。
[85] 最高人民检察院：“2021 年度十大行政检察典型案例”，最高人民检察院官网，https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202201/t20220124_542379.shtml，最后访问时间 2022 年 12 月 23 日。

中国知网 https://www.cnki.net

意而没有注意，应当预见而没有预见。[86]在行政处罚的立法中，通常并不对过失进行类型划分。在实践中过失的推定，可以通过行为人应当履行、有条件履行特定注意义务，但并未履行注意义务而进行推定。例如，在“沈某诉营口市站前区市场监督管理局、营口市站前区人民政府行政处罚与行政复议案”中，对于当事人在其所经营食品店的后厨内违法存放有过期调料和使用无生产日期香油的行为，营口市中级人民法院认为，当事人作为餐饮服务经营者，在采购中有义务查看所购香油的生产日期，并在日常实施经营的过程中有义务对生产原料进行经常检查。但当事人并未履行检查的注意义务，存放、使用过期原料，并将其加工制造的食品销售给不特定的民众使用，应认为其主观上存在重大过失。[87]

（三）行为人承担无过错举证的情形

行政处罚性法律规范对违法行为并不规定故意、过失的，推定行为人具有过错，由其承担无过错举证责任。一般而言，当事人能够证明其履行了必要且充分的注意义务，该客观违法行为及危害的发生仍具有不可预见性与不可避免性的，应视为当事人无主观过错，对其应不予处罚。[88]对于何为“必要且充分的注意义务”，则依行政处罚领域的不同而有所区别。通常而言，必要的注意义务，指为避免违法行为和违法状态的产生，而应采取的必要、充分的相关措施，以及应依法履行的法定义务。例如，根据《食品安全法》第一百二十四条，生产经营不符合食品安全标准的食品、食品添加剂的，行政机关得依法对其作出行政处罚。同时，根据该法第一百三十六条，对于依法履行进货查验义务的食品经营者，其能够证明其对于所购食品不符合标准不知情，且如实说明进货来源的，可以免予处罚。

当前，对于“无过错证明”应采用何种证明标准，以及证据证明力大小的问题，尚未存在相关立法加以明确。以“足以证明”为关键词进行案例搜索，亦未见法院对其所作分析和说明。由于不同领域的案件的证据特征、证明难度不一，“足以证明”的标准与违法的领域、违法行为所侵害的法益息息相关。正如学者尹培培所建议的，可以参照以下标准适用：“要做出裁判，法官必须对认定为判决基础的事项取得确信，这是一个原则。而要达到这种确信状态时，就叫做事项已被证明。这种诉讼上的证明所

[86] 参见陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 134-135 页。
[87] 参见辽宁省营口市中级人民法院行政判决书(2020)辽 08 行终 145 号。
[88] 《行政处罚法》第三十三条第二款规定：“当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。”

中国知网 https://www.cnki.net

必要的确信的程度不同于丝毫无疑义的自然科学的证明，而是只要通常人们在日常生活上不怀疑且达到作为其行动基础的程度就行。”[89]

[89] ［日］兼子一、［日］竹下守夫：《民事诉讼法》，白绿铉译，法律出版社 1995 年版，第 101 页。转引自尹培培：《论新<行政处罚法>中的“主观过错”条款》，载《经贸法律评论》2021 年第 3 期，第 56 页。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 行政法律责任消灭事由

行政法律责任伴随违法行为的成立而产生。对于行政违法行为，行政机关有权予以追究，并对其适用行政处罚权。但行政法律责任并非恒久不灭的，经法律特殊规定，行政机关对于特定违法行为处罚权丧失的；或者由于特定事实出现，国家机关对于行为人的行政处罚适用权无法再予行使的，行政法律责任归于消灭，对于行为人不再给予行政处罚。

第一节 行政处罚权丧失

出于敦促行政机关及时行使执法权、维护法的统一性与社会秩序的安定性等方面考虑，法律明确了在一定情形下，行政机关对于特定违法行为的处罚权不得再予行使，即行政处罚权的丧失。当前，导致行政处罚权丧失的事由主要有违法行为逾越处罚追诉时效，以及从轻追溯的情况下，行为人的行为不再被视为违法行为或不再受行政处罚。

一、逾越行政处罚追诉时效

行政处罚的追诉时效，是指对违法行为人依法给予行政处罚的有效期限，如果超出这一期限，则不能再对行政相对人作出行政处罚。[90]行政处罚权的行使，不宜悬之过久，而使处罚关系处于不确定状态，影响民众权益；但处罚权的行使期间亦不能过短，以免对社会秩序之维护有所影响。[91]由于不同违法行为的性质与危害不同，行政处罚的追诉时效依法律规定而不同。根据我国《行政处罚法》第三十六条，除法律法规另有规定外，一般违法行为的追诉时效为两年；涉及公民生命健康安全、金融安全且产生危害后果的，其追诉时效延长至五年；违法行为有连续或者继续状态的，追诉时效从行为终了之日起算。因此，由于不同违法行为的性质与危害不同，行政处罚的追诉时效依法律的规定而有所不同。对于逾越行政处罚时效不予行政处罚这一事由应从以下几个方面加以把握。

一是关于“二年内未被发现”的界定。就发现主体和发现起算时间点而言，除行政机关以外，公安、监察等行使社会公权力的机关，对于违法违纪的行为的发现同样

[90] 参见曹康泰：《行政处罚法教程》，中国法制出版社 2011 年版，第 97 页。
[91] 参见陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 308 页。

中国知网 https://www.cnki.net

具有法律效力。上述机关对于违法违纪行为只要启动调查、取证和立案程序，均可视为被“发现”。此外，对于群众举报后被认定属实的违法行为，以举报时间作为发现时间。[92]

二是关于“违法行为发生之日”的认定。一般而言，追诉期限从违法行为发生之日起算。其一，对于不以具体的侵害结果为要件的违法行为，行为实施之日即违法行为发生之日。例如，根据《治安管理处罚法》第三十条，违法制造爆炸性物质等危险物质的，行政机关应对其作出相应行政处罚。[93]由于制造危险物质等行为一经存在，即对社会管理秩序与人民群众的人身与财产安全形成了威胁状态，法律对于以上行为并未规定必须存在实害结果才能加以惩处，则此类行为违法行为一经实施，则视为违法行为发生之日。其二，对于以具体的侵害结果为要件的违法行为，实害结果发生之日，方为违法行为发生之日。例如，根据《治安管理处罚法》第二十九条第一项，行为人违反国家规定，侵入计算机信息系统，造成危害的，执法机关应对其作出相应行政处罚。则其行为的发生之日，应为侵入计算系统的行为带来危害结果之日。

违法行为具有连续与继续状态的，追诉时效从行为终了之日起算。违法行为的连续是指违法行为人以同一违法主观意识，连续实施多个性质相同的独立违法行为；违法行为的继续是指行为人作用于同一对象的违法行为在一定时期内同时处于继续状态。因此，违法行为具有连续、继续状态的，从最后一次违法行为发生之日、违法状态结束之日起算。例如，在人大法工委在对原住建部的工作回复中指出，对于违法发包、转包、分包、挂靠等行为的行政处罚追溯期限，应当从违法发包、转包、分包、挂靠的建筑工程竣工验收之日起计算。[94]在“沈某某诉贵州省黄平县自然资源局撤销行政处罚案”中，黄平县自然资源局对于沈某某违法占地的行为作出行政处罚，并要求其限期拆除违法建筑。沈某某提起行政诉讼，诉称其对涉案建筑物管理使用已达6年之久，黄平县自然资源局在此期间并未进行追究，因此其占地行为发生六年后的行政处罚已超过行政处罚追诉时效，应对其不予行政处罚。对此，法院认为，沈某某之占地行为，

[92] 《全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会关于提请明确对行政处罚追诉时效“二年未被发现”认定问题的函的研究意见》（法工委复字〔2004〕27号）规定：“公安、监察、法院、纪检监察部门和司法行政机关作为行使社会公权力的机关，其对于违法违纪行为的发现都应具有《行政处罚法》规定的法律效力。因此上述任何一个机关对律师违法违纪行为只要启动调查、取证和立案程序，均可视为“发现”；群众举报后被认定属实的，发现时效以举报时间为准。”

[93] 《行政处罚法》第三十条规定：“违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。”

[94] 参见《全国人大常委会法制工作委员会对建筑施工企业母公司承接工程后交由子公司实施是否属于转包以及行政处罚两年追溯期认定法律适用问题的意见》（法工办发〔2017〕223号）。

中国知网 https://www.cnki.net

在违法占地未恢复原状之前，应视为处于继续状态，因此其行为并未终了，行政机关所作出的行政处罚未超越法定追诉时效。[95]

此外，值得注意的是，在部分违法行为中，违法行为结束后，其行为所造成的不法状态仍可能持续，即违法行为与违法结果处于两种不同的状态，这一现象在刑法中被称为“状态犯”。例如行为人盗窃之后，尽管盗窃行为已经结束，但是非法占用他人财物的状态一直在持续。在刑法通说中，对于状态犯之追诉时效，从行为结束之日起算，而非违法结果的持续状态终止起算。在当前我国的行政处罚实践中，“违法行为持续”与“违法结果持续”的区分呈现较为模糊的状态。例如，违法进行建设、施工的行为结束于建筑竣工之日，违法建筑物在竣工后理论上系作为违法结果而长期持续。而对于违法建筑，住建部主张：“违法规划许可、工程建设强制性标准进行建设、设计、施工，因其带来的建设工程质量安全隐患和违反城乡规划的事实始终存在，应当认定其行为具有持续状态”，全国人大法工委对该意见加以认可。[96]此外，在工商登记领域对于追诉时效的起算点同样存在较大争议，其中一种观点主张，以欺骗手段等违法方式取得工商登记的行为，在行为人更正工商登记之前，或者行为人停止使用虚假取得的营业执照之前，违法工商登记的行为处于继续状态。比如，在“某（北京）国际商业管理有限公司上诉北京市工商行政管理局东城区分局工商行政处罚案”中，审理法院主张“该公司自始至终都未自行纠正其违法行为，其违法行为所产生的后果仍处于继续状态”，由此认定行政机于该工商登记五年后再对行为人作出处罚的行为合法。[97]

但违法行为的继续与违法结果的继续并不能简单等同。若出于行政管理秩序的需要，对“违法行为的继续状态”进行任意定义，不但有违法理与常理，而且易于导致法制上的不统一，削弱法的安定性与可期待性。比如，在不符合城市规划的建筑建成数十年后，以违建行为处于持续状态为由对行为人作出行政处罚，一方面不符合大众对于“违法行为仍在继续”的认知，另一方面往往会导致行政处罚缺乏事实与法律依据局面的出现。例如，在建筑建成数十年后，城市规划往往发生较大改变。若以违法建设时的城乡规划为处罚事实依据，认为行为人违反了数十年前的城乡规划，拟对行为人作出行政处罚，则其违法行为已逾越行政处罚的追诉期限；若以处罚时的城乡规

[95] 最高人民法院：“耕地保护典型案例”，最高人民法院官网，https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-279511.html，最后访问时间 2022 年 12 月 19 日。
[96] 参见《住房城乡建设部关于违反规划许可、工程建设强制性标准建设、设计违法行为追诉时效有关问题的请示》（建法函[2011]316 号）；《全国人大法工委对关于违反规划许可、工程建设强制性标准建设、设计违法行为追诉时效有关问题的意见》（法工办发〔2012〕20 号）。
[97] 北京市第二中级人民法院行政判决书（2014）二中行终字第 106 号。

中国知网 https://www.cnki.net

划为处罚之事实依据，则行为人建设时并未存在相应的城乡规划，以不存在之事实对行为作出处罚违背基本的法治原则和理念。同样地，在相应行政处罚性法律规范发生变更的时候，这一悖论同样难以消除。

因此，对于行政法上的状态犯，违法结果之持续并不妨碍时效之起算，违法行为一经完成或者终止的，即便违法结果仍呈现持续状态，仍应从违法行为结束之日计算行政处罚追诉时效。[98]这一观点也在行政处罚实践得到了支持。例如，在“建平县某厂诉建平县市场监督管理局工商行政处罚案”中，建平县市监局认为江某某投资设立的某厂存在伪造材料骗取工商登记的违法行为，作出行政处罚决定。法院在该案中认为，伪造材料骗取公司工商登记的行为一经完成，则违法状态已经结束，行政处罚追诉时效应当从工商登记完成之日起算，而不应认为违法行为处于持续状态。[99]对于以上观点可能存在质疑：否认违法结果作为违法行为状态的延续，可能导致违法行为带来的危险始终存在，不利于行政管理秩序的维护。但应予指出的是，行政处罚并非纠正违法行为的唯一途径，在违法行为超过行政处罚追诉时效后，行为人仍未对其违法行为进行纠正与补救，导致违法结果长期对社会公共利益和公共秩序造成不良影响的，行政机关仍有权责令当事人改正或者限期改正违法行为，消除违法行为带来的影响，以补救遭到侵害的社会管理秩序，维护正常行政管理秩序；行为人的违法结果之持续，导致了构成新的违法行为的产生的，则对违法人可追究其对于新违法行为的行政法律责任。

二、法律适用从旧从轻

“法不溯及既往”是处理新旧法律适用问题的一项基本原则。在对违法行为人的国家惩戒上，该原则衍生出“从旧兼从轻”原则，即通常情况下法律规范不具有溯及力，对于违法行为原则上应当适用行为时生效的法律规范；但若适用新的法律规范对于行为人更为有利，则应当对行为人适用新的法律规范。《立法法》第一百零四条对“从旧兼从轻”原则进行了明确，[100]而本次《行政处罚法》修订，新增了关于行政处罚法律适用溯及力的规定，将“从旧兼从轻”原则明确引入行政处罚领域，弥补了《行政处罚法》在新旧行政法律规范适用领域的空白，从而确立了在行政处罚中，法

[98] 参见陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 313 页。
[99] 辽宁省朝阳市中级人民法院行政判决书（2015）朝行终字第 00028 号。
[100] 《立法法》第一百零四条：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”

中国知网 https://www.cnki.net

律规范适用从旧、从轻的原则。[101]对于特定行为发生后、行政处罚决定作出前，行为相对应的处罚性行政法律规范发生变更的，应进行以下处理：一是行为时的行政处罚法律规范不认为是违法，变更后的法律规范认为是违法的，适用行为时的法律规范，而不能以新的法律规范追究行为人的法律责任；二是行为时的法律规范认为是违法，新法不认为是违法的，应适用新法，而不再以旧法追究行为人的违法责任；三是行为时的法律规范与新的法律规范均认为是违法，但二者在量刑上不一致的，原则上应当按照行为时的法律规范追究责任，但如果新规范如果在量刑上较轻或者对行为人不予行政处罚的，遵循新规范之规定。

因此，根据《行政处罚法》第三十七条，原违法行为终了后，在新法中不构成违法行为或者依法应不予行政处罚的，行政机关不再对行为人作出行政处罚决定。例如，根据 2021 年 4 月 29 日生效的《食品安全法（2021）》第三十五条第一款，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得食品生产经营许可。[102]而根据《食品安全法（2018）》第三十五第一款，不需要取得生产经营许可的即可销售食品范围仅包括销售农产品的情形，而不包括“仅销售预包装食品”的情形。[103]因此，在《食品安全法（2018）》生效期间，对于未经食品生产经营许可从事销售预包装食品的行为，行政机关应根据该法第一百二十二条第一款进行处罚。[104]但行为人于 2021 年 3 月销售预包装食品被立案调查，行政机关在《食品安全法（2021）》生效实施后尚未作出行政处罚决定的，不再对行为人作出行政处罚决定。

第二节 行政处罚对象灭失

行为人不具有承担行政处罚法律责任的可能的，即使没有法律法规的规定，行政法律责任也会归于消灭，此即行政处罚对象的灭失。行政处罚对象灭失的情形主要有作为当事人的自然人死亡、以及作为当事人的法人或者其他组织终止，无法人或者其

[101] 《行政处罚法（2021）》第三十七条明确：“实施行政处罚，适用违法行为时发生的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”

[102] 《食品安全法（2021）》第三十五条第一款：“国家对食品生产国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品和仅销售预包装食品的，不需要取得许可。仅销售预包装食品的，应当报所在地县级以上地方人民政府食品安全监督管理部门备案。”

[103] 《食品安全法（2018）》第三十五条第一款：“国家对食品生产经营实行许可制度。从事食品生产、食品销售、餐饮服务，应当依法取得许可。但是，销售食用农产品，不需要取得许可。”

[104] 《食品安全法（2018）》第一百二十条第一款：“违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。”

中国知网 https://www.cnki.net

他组织承受其权利义务两种典型情形。对于以上两种情形的处理，可见于部分领域的行政处罚程序规定中。（详见表 1）

表 1 现行立法规定的行政法律责任事实消灭事由

法律规范	条文内容
《市场监督管理行政处罚程序规定（2022）》	第四十七条：“因涉嫌违法的自然人死亡或者法人、其他组织终止，并且无权利义务承受人等原因，致使案件调查无法继续进行的，经市场监督管理部门负责人批准，案件终止调查。”
《中华人民共和国海关办理行政处罚案件程序规定(2021)》	第五十三条：“经调查，行政处罚案件有下列情形之一的，海关可以终结调查并提出处理意见：……（三）作为当事人的自然人死亡的；（四）作为当事人的法人或者其他组织终止，无法人或者其他组织承受其权利义务，又无其他关系人可以追查的……” 第七十一条：“海关负责人应当对行政处罚案件进行审查，根据不同情况，分别作出以下决定：……（四）符合本规定第五十三条第三项、第四项规定的情形之一的，撤销案件……”
《公安机关办理行政案件程序规定（2020）》	第二百五十九条：“经过调查，发现行政案件具有下列情形之一的，经公安派出所、县级公安机关办案部门或者出入境边防检查机关以上负责人批准，终止调查：……（三）违法嫌疑人死亡的……终结调查时，违法嫌疑人已被采取行政强制措施的，应当立即解除。”
《邮政行政处罚程序规定（2020）》	第三十七条第三款：“因涉嫌违法的自然人死亡或者法人、其他组织终止，并且无权利义务承受人等原因，致使案件调查无法继续进行的，经邮政管理部门负责人批准，案件终止调查。”
《旅游行政处罚办法（2013）》	第三十五条：“有下列情形之一的，可以终结调查：……（三）作为当事人的自然人死亡的；（四）作为当事人的法人或者其他组织终止，无法人或者其他组织承受其权力义务，又无其他关系人可以追查的……调查终结后，对违法行为应当给予处罚的，执法人员应当提出行政处罚建议，并报案件承办机构或者旅游主管部门负责任人批准；不予处罚或者免予处罚的，报案件承办机构或者旅游主管部门负责人批准后，终止案件。”
《环境行政处罚办法（2010）》	第四十四条：“【调查终结】有下列情形之一的，可以终结调查：……（三）作为当事人的自然人死亡的；（四）作为当事人的法人或者其他组织终止，无法人或者其他组织承受其权利义务，又无其他关系人可以追查的……”
《国家外汇管理局关于印发<检查处理违反外汇管理行为办案程序>的通知(2008》	第五十四条：“有下列情形之一的，外汇局可以终结调查：……（三）作为当事人的自然人死亡或者丧失行为能力；（四）作为当事人的法人或者其他组织终止，并且无其他法人或者其他组织承接其权利义务……” 第五十五条：“对已经终结调查的违反外汇管理行为，外汇局应当制作检查报告，报经本外汇局主管负责人进行审查，并根据下列不同情况作出处理：……（四）作为当事人的自然人死亡或者丧失行为能力的，案件终结；（五）作为当事人的法人或者其他组织终止，并且无其他法人或者其他组织承接其权利义务的，案件终结……”

综合以上市监、海关、公安、邮政等领域的行政处罚程序规定，行政处罚案件未结案，自然行为人死亡、作为当事人的法人或者其他组织终止，并且无其他权利义务承受人、又无其他关系人可以追查的，其处理方式一般为终止（终结）调查并结案。该处理思路，与刑事违法行为的追究较为一致。[105]这是由于行为人不具有承担行政处罚法律责任的可能的，处理对象已不存在，在无权利义务承受人或者其他可以追查的关系人的情况下，无法进行调查处理。同时，即使经过调查处理、作出行政处罚决定，行政处罚制裁并预防违法行为的目的也无法得到实现，从而使该行政行为失去实际意义。因此，行为人不具有承担行政处罚法律责任的可能的，其违法行为带来的惩戒性行政法律责任由之消灭。

[105] 根据《刑事诉讼法》第二百九十七条：“被告人死亡的，人民法院应当裁定终止审理，但有证据证明被告人无罪，人民法院经缺席审理确认无罪的，应当依法作出判决。　　人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，被告人死亡的，人民法院可以缺席审理，依法作出判决。”

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 免予行政处罚事由

尽管违法行为均造成了侵害法益的结果或者带来侵害法益的危险，但出于行政合理性、实质行政法治以及行政效率的要求，仍有必要进一步考虑该违法行为的实质危害性，以及是否具有以行政处罚的手段惩戒违法行为的必要性。介于行政处罚所欲达成的目的，如保护交通安全或者改善环境等，与行政处罚这一手段加以权衡，对于可以采用如劝导、纠正、警告、强制等行政手段，能够更有效地达成行政目的的，即无需加以处罚。[106]因此，法律仍规定了法定免罚事由与裁量免罚事由。符合法定免罚事由，或经行政机关裁量得免予行政处罚的，行政机关应坚持“处罚与教育相结合的原则”，对行政相对人免予行政处罚，并进行批评、教育、监督，引导行为人纠正违法行为并消除行为带来的消极影响。

第一节 法定免罚事由

当前我国行政法律规范中所明确的法定免罚事由主要包括“无危害性不罚”以及“一事不再罚”两种情形。

一、无危害性不罚

根据《行政处罚法》第三十三条第一款，对于符合“违法行为轻微”、“及时改正”、“没有造成危害后果”三个构成要件的违法行为，应依法不给予相对人行政处罚。[107]这一规定亦被纳入《反不正当竞争法》、《危险废物转移管理办法》、《化妆品生产经营监督管理办法》等部门行政处罚法律规范中。[108]但无论是在总则性的《行政处罚法》层面，抑或是在地方行政处罚法律规范层面，均缺乏对于该构成要件统一、客观、明确的判断标准，导致行政执法的过程中存在着主观恣意较大的问题。对此，本文尝试对具体行政领域的执法、司法实践进行研究与总结，寻求共同的判断标准。

---

[106] 洪家殷：《行政罚法论》，五南图书出版公司 2006 年版，第 61 页。

[107] 《行政处罚法》第三十三条第一款规定：“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。”

[108] 《反不正当竞争法》第二十五条规定：“经营者违反本法规定从事不正当竞争，有主动消除或者减轻违法行为危害后果等法定情形的，依法从轻或者减轻行政处罚；违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚”；《危险废物转移管理办法》第二十九条第三款规定：“违反本办法规定，未规范填写、运行危险废物转移联单，及时改正，且没有造成危害后果的，依法不予行政处罚；主动消除或者减轻危害后果的，生态环境主管部门可以依法从轻或者减轻行政处罚”；《 化妆品生产经营监督管理办法》第五十九条第二项规定：“监督检查中发现化妆品注册人、备案人、受托生产企业违反国家化妆品生产质量管理规范检查要点中一般项目规定，违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。”

中国知网 https://www.cnki.net

（一）违法行为轻微

《行政处罚法》第 5 条违法行为轻微与否提供了判断方向，即依据违法行为的事实、性质、情节以及危害程度展开判断，但该条同样未能够提供明确的判断标准。对此，有学者尝试从反面排除轻微违法行为，指出特定违法行为不构成轻微违法的范畴：一是应承担人身自由罚、资格罚和较大数额财产罚的违法行为，二是根据法律规定应同时处以多种类型行政处罚的违法行为，三是故意实施具有较大主观恶意的违法行为，四是责令改正而拒不改正的违法行为。[109]但反面排除仅有助于缩小轻微违法行为的判断范畴，但并未提供确定轻微违法行为的有效判断标准。因此，通过对行政法律规范中具体免罚条款进行研究，以及对行政处罚执法、司法实践中个案经验加以凝练，总结出具有共性的判断标准，或为有效的解决之道。经过研究与总结可以发现，数量多少、作用范围大小、主观过错大小、危害可能性大小等因素是判断违法行为轻微与否的重要标准。

1. 违法行为的数量因素

与违法行为相关的数量大小，如涉及到的金额大小、违法行为次数多少、违法行为持续时间长短等数量因素，往往关系到违法行为的严重程度。

（1）涉案财物价值以及违法所得

在通过不法手段而牟取非法财产性权益的违法行为中，涉案财物价值以及违法所得的多少，是判断行为轻微与否的重要因素。通常认为，涉案财物价值较小、违法所得较少的行为，其行为性质较为轻微。例如，《安徽省市场监督管理轻微违法违规经营行为免罚清单》第（五十）明确，违反《安徽省价格监督检查条例》第十七条、十八条的规定，违法收费金额较少，且主动将违法收费金额退还给被收费单位或个人的，属于轻微违法违规经营行为，对行为人不予行政处罚。在“张某某诉上海市浦东新区市场监督管理局处罚决定案”（以下简称“张某某案”）中，审理法院认为，第三人对食品标签中存在的问题不负主要责任，且第三人违法经营食品的货值金额和违法所得较少，行为人之违法行为轻微。[110]在“任某某与东莞市市场监督管理局食品药品安全行政管理纠纷案”（以下简称“任某某案”）中，审理法院认为，违法行为人违法销售超过保质期的食品，但由于涉案商品品种单一、数量极少、货值较低，属轻微违法行为，行为人能够及时采取纠正措施且未造成危害，行政机关对其作出不予行政处罚，

[109] 谢红星：《不予行政处罚行为的确定》，载《学术界》2022 年第 7 期，第 67-69 页。
[110] 上海市第一中级人民法院二审行政判决书(2014)沪一中行终字第 266 号。

中国知网 https://www.cnki.net

并无不当。[111]反之，若涉案财物的价值较大、违法所得较多，行政机关、司法机关往往作出该行为不属于轻微违法行为的认定。例如，在“安徽省某化纤织造有限公司诉阜阳海关海关行政处罚案”中，行为人违法擅自将免税进口的货物抵押给银行以办理贷款。法院经审理认为，涉案货物价值高达千万元，已明显超过违法行为轻微的界限，对该行为应依法进行处罚。[112]

（2）违法行为的次数

违法行为的次数在一定程度上能够反映行为人的主观过错程度以及人身危险性，从而成为部分行政处罚中行政机关加以考量的因素。例如，《天津市港航领域轻微违法行为免罚暂行办法》第三条第一款规定：“本办法所称轻微违法行为，是指违法行为人在同一年内首次出现列入《免罚清单》中的事项。”在“罗某某诉吉安县公安局交通警察大队处罚案”（以下简称“罗某某案”）中，再审法院认为，行为人在驾驶机动车时多次不按照交通标线行驶，该行为是对平等、有序的社会价值的破坏，明显不符合《行政处罚法》第二十七条第二款（现第三十三条第一款）规定的情形，对社会造成了危害后果，其主张应不予行政处罚的理由不能成立。[113]但应予指出的是，尽管违法行为的次数能够体现其主观恶性，行为人多次实施同一违法行为，可能对社会秩序带来较高隐患，从而不宜将其视为轻微违法行为，但是，对于有多次违法的行为人，不宜一律否定其“违法行为轻微”认定的可能性，而应在具体案件中进行实际判断。只有次数与行为严重性密切相关的，才能够对其不适用法定不罚条款。部分“免罚清单”中直接将“初次违法”作为轻微违法的充分必要条件，是对“法定不罚”与“裁量不罚”的混淆，事实上缩小了法定不罚的适用范围。

（3）违法行为持续时间

在行政处罚实践中，违法行为持续时间的长短往往作为行为情节轻重的重要判断因素。例如，在“黄某某与太仓市公安局、太仓市人民政府行政复议二审行政判决书”中，审理法院认为，原审第三人确实存在辱骂他人的违法行为，但就其违法行为的持续时间及社会危害程度而言，情节属于特别轻微，因此公安局对其作出不予行政处罚决定并无不当。[114]在“佛山市某鞋材有限公司与佛山市生态环境局、佛山市人民政府

[111] 广东省东莞市第一人民法院行政判决书（2018）粤 1971 行初 649 号；广东省东莞市中级人民法院行政判决书（2019）粤 19 行终 86 号；广东省高级人民法院行政判决书(2019)粤行申 2595 号。

[112] 安徽省合肥市中级人民法院行政判决书(2019)皖 01 行初 195 号；安徽省高级人民法院行政判决书(2020)皖行终 181 号。

[113] 江西省高级人民法院行政判决书(2017)赣行申 314 号。

[114] 江苏省苏州市中级人民法院行政判决书(2019)苏 05 行终 590 号。

中国知网 https://www.cnki.net

罚款案”中，佛山市生态环境局认为，行为人在建设项目环境影响评价文件因正当事由未获批的情况下，其在2009年至2019年近十年的时间内，未依法重新办理建环评审批手续，一直正常生产经营、放任自身违法行为持续，该行为不属于轻微违法行为。法院经审理查明，亦认可这一说法，指出当事人的生产项目于2009年3月投入生产，但直至市环境局2019年8月检查时，其环境保护设施未完全建成且未经验收即投入生产的违法行为依然持续，且该厂存在废气直接排放的行为，明显不符合“违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果”而可以不予处罚的情形。[115]

2. 违法行为作用的范围大小

在部分违法行为中，作用范围的大小构成判断违法行为轻微与否的重要标准。作用范围包括物理空间意义上的作用范围，以及社会环境意义的作用范围。通常认为，违法行为作用的范围较小的，其行为性质较为轻微。一是物理空间的作用范围。在环境类行政处罚以及其他涉及土地等空间因素的行政处罚中，违法行为作用的土地、水体等物理空间面积的大小。例如，根据《北京水务领域轻微违法行为免罚清单》，违法行为作用的土地面积是影响行政处罚作出与否的重要因素。[116]在“刘某某等与南通市公安局崇川分局等处罚上诉案”中，违法行为人将行为人经过平整的通道挖开，对此，行政机关认为行为人破坏的面积较小，其破坏的道路表面财产极其轻微，道路平整性容易恢复，其行为情节特别轻微。经审理，这一观点得到人民法院认可。[117]在“张某甲、张某乙等诉金华市国土资源局不履行法定职责案”中，行为人未经依法批准，擅自在其厂区的田间小路上（该土地类别为设施农用地）建造地下污水池。行政机关经调查认为，行为人未经批准占用田间小路建造地下污水池的行为违反了《土地管理法》第二条第三款规定，属非法占地行为，但由于其使用面积较小，且污水池上面水泥硬化部分与路面保持平整，并不影响田间耕作出行，因此可认定其违法行为轻微而对其不予行政处罚。法院经审理认为，行政机关认定行为人情节轻微而不予行政处罚并无不当。二是社会环境意义的作用范围，比如发布违法广告、其他违法信息的受众群体范围等。通常认为，违法行为的作用范围越广，其潜在危害性越大，行为性质越为严重；作用范围小、受众范围小的违法行为，其潜在危害性较小，行为性质则较为轻微。

[115] 广东省佛山市中级人民法院行政判决书(2021)粤06行终339号。

[116] 《北京税务领域轻微违法行为》规定：“下列违法行为并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚；或者初次违法且危害后果轻微并及时改正的，不予行政处罚：一、违反《中华人民共和国水土保持法》第十八条第二款，在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发面积在50平方米以内的；二、违反《中华人民共和国水土保持法》第二十条第一款，在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦终止农作物在50平方米以内的……”

[117] 江苏省南通市中级人民法院行政判决书(2016)苏06行终461号。

中国知网 https://www.cnki.net

[118]例如，在“方某某炒货店案”中，再审法院认为，行政机关在作出行政处罚的过程中，应全面综合考虑违法情形进行处罚，本案中行为人主要在经营场所内外及外包装袋上展示广告，与通过电视、网络等大众传媒发布广告相比，此种方式作用范围较小，行政机关实施行政处罚时，应全面综合考虑违法情形，将该事实纳入考虑。[119]

3. 违法行为人主观过错大小

违法行为人的主观因素是影响行为性质的重要因素。一般认为，行为人实施违法行为时主观恶意越大的，其行为性质越为严重。在行为人实施违法行为主观恶意较小，乃至不具有主观故意的情况下，可结合其行为的具体情节，认定该行为是否属于轻微违法行为。例如，根据《鞍山市发展和改革委员会包容免罚清单》，对于部分违反《石油天然气管道保护法》的违法行为，违法行为并非出于故意，且未造成长输油气管道外部安全隐患或事故的，责令行为人停止违法行为，对行为人不予行政处罚。在“江苏某科技有限公司诉江苏省工商管理局工商行政处罚案”（以下简称“江苏某科技有限公司案”）中，二审法院认为，在商标侵权案件中，行为人的主观过错程度是判断商标侵权行为性质和情节的重要因素。由于在案涉注册商标核准之前，侵权人的所使用的字号已经具备一定的知名度，因此可以认定其在案涉侵权标识中使用其字号具有合理性，而不具有侵权的主观故意，可以认定主观过错轻微、行为情节较为轻微。[120]

4. 危害可能性

在认定轻微违法行为的过程中，违法行为的危害可能性是行为轻微与否的重要判断因素。一般认为，对行政管理秩序以及社会秩序造成的危害可能性较小的违法行为，其行为性质较为轻微。部分行政法律规范明确规定，仅仅违反管理性行政规定，但并未造成、不足以造成较大的不良影响及危害后果的行为，对其应先予责令改正，拒不改正的，再处以行政处罚。对于这类违法行为，行为人符合免罚条款的，行政机关应依法对其免予行政处罚。例如，根据《食品安全法》第一百二十五条第二款，存在瑕疵的食品及添加剂的标签、说明书，不影响食品安全且不会对消费者造成误导的，由有权部门责令改正，拒不改正的，对其处以罚款。这一条款即是“无危害性不罚”在具体行政处罚领域的应用，“不影响食品安全且不会对消费者造成误导”意味着，该瑕疵食品标签或者说明书不仅在当前并未造成危害结果，且可以预见其在未来对于已经

[118] 金华市婺城区人民法院行政判决书(2014)金婺行初字第 41 号。
[119] 浙江省高级人民法院行政裁定书(2019)浙行申 64 号。
[120] 江苏省高级人民法院行政判决书(2013)苏知行终字第 0004 号。

中国知网 https://www.cnki.net

购买的民众不会产生食品安全隐患问题，因此可以认为该瑕疵行为是轻微违法行为。对于该行为，行为人能够及时改正的，行政机关应依法不予行政处罚，而不具有裁量空间、不得附加其他条件，否则属于违法处罚行为。例如，《珠海市市场轻微违法行为免罚清单》以“属于首次被发现的，违法情节轻微，未造成严重后果的”作为对该行为免予行政处罚的条件，增加了“首次被发现”的条件，不符合《食品安全法》、《行政处罚法》的规定和要求。

当前，各地加强落实包容审慎监管理念，不断优化营商环境，纷纷出台“免罚清单”。大量危害可能性较小或者不具有危害可能性的违法行为，被纳入免罚清单中。例如，《鞍山市发展和改革委员会包容免罚清单》明确，对于粮食经营台账记录不规范，并及时改正的违法行为不予行政处罚；《包头市卫生健康领域轻微违法行为免罚清单》明确，对于未依法办理执业地点变更手续在本机构从事诊疗技术规范规定的护理活动等行为，依法可以责令其限期改正，行为人行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，对行为不予行政处罚。这是由于在以上违反行政管理程序性规定的违法行为中，其违法行为仅仅是在违反法律规范层面受到否定的法律评价，而并未产生危害结果，且其危害可能性较小，一经行为人及时改正，便能够彻底防止违法行为发生危害性。在行政执法、司法实践中，这一标准也被广泛应用，例如，在“茂名某环保资源开发有限公司诉茂名市生态环境局、茂名市人民政府行政处罚及行政复议纠纷案”（以下简称“茂名某公司案”）中，当事人永诚公司在转移飞灰的过程中，不按照国家规定填写危险废物转移联单。执法机关在责令其改正违法行为后，作出了罚款 15 万元的行政处罚决定。对此，法院经审理认为，永诚公司长期填写自制的纸质转移联单，并按照规定申报飞灰处置情况，在转移废物过程中尚未出现影响或危害环境的情况，且其认错态度良好，积极纠错，应依法对其不予行政处罚，由此撤销了案涉行政处罚决定。[121]

相反，在行政处罚作出时未造成危害后果，该行为本身潜藏着较大危害可能性的违法行为，则不构成轻微违法行为。例如，在“银某与银川市市场监督管理局金凤区分局、银川市市场监督管理局行政处罚、行政复议纠纷案”中，消费者在案涉超市内购买到货值 356.5 元、共 3 个品类的过期食品，向行政机关投诉举报。行政机关调查核实该超市确实存在非法售卖过期食品的违法行为，遂对其作出行政处罚。超市经营者银某主张其售卖行为未造成危害后果，不应对其进行处罚。对此，行政机关认为，其

[121] 广东省高级人民法院：“2019 年度广东法院行政诉讼十大典型案例”，广东法院网，https://www.gdcourts.gov.cn/index.php?v=show&cid=170&id=55546，最后访问时间 2022 年 12 月 23 日。

中国知网 https://www.cnki.net

混卖过期食品与保质期内食品的行为违反了《食品安全法》，案涉过期食品对于人身健康安全具有较大的隐患，故该情形不属于轻微违法而应不予行政处罚的情形。这一观点亦得到法院认可。[122]

此外，部分学者认为，涉案物品的数量，该行为是否违反多个法律规范、构成“想象竞合犯”，以及法律规范是否明确对该行为处以多类型的处罚等因素，同样可能对违法行为轻微与否的认定产生影响。[123]

（二）及时改正

及时改正是指行为人对于其过错具有良好的认错及纠正态度，能够在违法行为发生后积极采取措施纠正违法行为。行政处罚的主要目的为对违法行为人加以惩戒，并预防其再犯。对于未造成危害的违法行为，行为人能够及时加以改正的，其社会危害性和再犯的可能大大减小。在行政处罚的过程中，以下两种情形应予区分：一是“及时改正”作为违法行为形式违法性的构成要件的情形，二是“及时改正”作为“无危害性不罚”这一免罚事由的构成要件的情形。在大量行政法律规范中存在明确规定，对于行为人的违法行为，应首先责令其限期改正，逾期未改正的，再处以行政处罚。在该情形下，“经限期改正而不改正或者逾期改正”是违法行为应受行政处罚的前提条件。只要行为人在行政机关给予的合理期限内加以改正，则该行为仅产生补偿性法律责任，而未产生惩戒性行政法律责任，行政机关即不得对行为人作出行政处罚。例如，根据《石油天然气管道保护法》第五十条，执法机关查明行为人未依法对管道进行巡护、检测和维修的，首先应当责令行为人限期改正，行为人在规定合理期限内依法对管道巡护、检测、维修的，其行为由于违法构成缺失而不受行政处罚。[124]而本章所讨论的，是指第二种情形，即“及时改正”并不属于违法行为的消极构成要件，而是作为法定免罚事由的构成要件之一。在该情形下，当事人之行为已满足违法行为之构成要件，其惩戒性法律责任已产生，行政机关仍应考量其是否符合免予承担责任的情形。“及时改正”这一要件，主要涉及到以下两个方面的内容。

一是对于“及时”的理解。对于“及时”的理解，在学界上主要存在两种观点。观点之一认为，是认为“及时”是指行为人在危害结果发生之前，积极采取改正措施，

[122] 宁夏回族自治区银川市中级人民法院行政判决书(2020)宁 01 行终 75 号。

[123] 参见张红：《免予行政处罚制度的现实困境与解决之道》，载《中国司法》2020 年第 4 期，第 60 页；谢红星：《不予行政处罚行为的确定》，载《学术界》2022 年第 7 期，第 68 页等。

[124] 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第五十条规定：“管道企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分：（一）未依照本法规定对管道进行巡护、检测和维修的……”

中国知网 https://www.cnki.net

并有效防止了危害结果的发生。仅在此情况下，行为人的措施得认定为“及时”；在危害结果发生后采取措施的，不再将其视为法定免罚因素，而仅能在量罚时加以考虑。[125]观点之二认为，“及时”不仅要求行为人在危害结果发生之前采取措施，同时要求该改正措施是行为人发现违法行为后的主动纠正，而不是行政执法人员发现后责令其纠正后采取的措施。[126]但无论是行为人之主动纠正，抑或是行政执法人员责令后纠正，其改正措施均有助于法益的维护，能够实现行政处罚“维护公共利益和社会秩序、保护公民、法人及其他组织的合法权益”的目的。此外，对于在责令后纠正的轻微违法行为不予行政处罚，可以有效避免对于由于“不知法”而实施轻微违法行为的当事人的处罚，提升行政处罚的合理性，提升行政执法温度。因此，应本着有利于相对人的解释原则，只要行为人自行纠正或者经劝告、责令后纠正其违法行为，即应认为其符合“及时”这一构成要件。这一观点亦为实践中的主流观点，例如，《天津市港航领域轻微违法行为免罚暂行办法》第三条第二款规定：“本办法所称及时纠正，是指违法行为人在执法单位发现违法行为前已主动改正的，或者在执法单位责令限期改正的期限到期前改正的。”在“张某某案”中，法院认为行为人在案发后能够积极提供相关证照和报告，配合案件查处，并主动督促供货商整改，符合“及时改正”要件。[127]在“茂名某公司案”中，法院认为，行为人存在未按国家规定填写危险废物转移联单的违法行为，但其违法行为轻微，在收到整改通知后立即进行了整改，纠错行为积极，及时改正了其违法行为。[128]在“江苏某科技有限公司案”中，二审法院认为，行为人在行政机关进行调查处理期间，采取了一系列措施，积极改正，符合“及时改正”之要件。[129]

二是对于“改正”的理解。改正即行为人对于补偿性行政法律责任的承担。是指违法行为人依法履行法定义务，停止违法行为，消除其行为带来的不良法律后果，并恢复原状。改正的方式主要有以下几个方面，一是当事人具结悔过，即行为人主观上对违法行为具有悔过之意，并在客观上表现为忏悔之意及不再犯的保证；二是恢复原状，即被侵害的对象具有物质上的可还原性时，行为人应将其恢复到原来的状态；三

[125] 参见尹培培：《不予行政处罚论——基于<我国行政处罚法>第 27 条第 2 款规定之展开》，载《政治与法律》2015 年第 11 期，第 154 页。
[126] 参见张红：《免予行政处罚制度的现实困境与解决之道》，载《中国司法》2020 年第 4 期，第 60 页。
[127] 上海市第一中级人民法院二审行政判决书(2014)沪一中行终字第 266 号。
[128] 广东省高级人民法院：“2019 年度广东法院行政诉讼十大典型案例”，广东法院网，https://www.gdcourts.gov.cn/index.php?v=show&cid=170&id=55546，最后访问时间 2022 年 12 月 23 日。
[129] 江苏省高级人民法院行政判决书(2013)苏知行终字第 0004 号。

中国知网 https://www.cnki.net

是退还原物，即存在被侵占的物品时，行为人返还原物，或者通过以金钱折抵的方式返还；四是回归到法律已确立的秩序状态，恢复行政管理秩序与社会秩序的有序性。[130]因具体违法行为的不同，“改正”的表现形式也有所不同，如停止违法行为、积极配合调查取证、退还非法侵占财物、赔偿受侵害人损失、限期拆除违法建筑等。例如，在“江苏某科技有限公司案”中，二审法院认为，行为人在行政机关行政处理期间，积极配合调查，主动承认错误并更换了案涉侵权产品的外包装袋，应认定其及时纠正了商标侵权的违法行为。[131]在“济南市历城区市场监督管理局与济南某影城有限公司等行政处罚及行政复议再审案”中，山东省高级人民法院认为，在行政机关办理该案期间，行为人违法行为轻微，且其及时主动停止未经许可擅自从事电影放映活动这一违法行为，并主动上交账目及放映设备，积极配合调查取证，此为及时采取了改正措施。因此，行为人在违法行为发生后，及时采取措施，停止违法行为、防止危害结果发生，使得被破坏的法律关系和社会秩序得到修复的，应认定其符合“及时改正”之要件。[132]应予注意的是，在行政机关对违法行为进行调查处理的过程中，应对行为人陈述、申辩的权利加以保障，行为人进行陈述、申辩的，不得将其认定为“未及时改正”。

（三）没有造成危害后果

危害结果包括一般意义上的“危害结果”和“危险”两种类型，表现为“可能的危害结果”和“实际的危害结果”两个阶段。[133]可能的危害结果即指行为人对法益所创造的现实具体的危险状态，实际的危害结果则指的是行为人的行为直接造成的法律所保护利益的减损。在部分违法行为中，行政法律责任的产生以实害结果或者危险状态的存在为前提。实害结果或危险状态缺失的，行为人因惩戒性行政法律责任未产生而不受行政处罚，对该行为无需考虑法定免罚事由。例如，根据《治安管理处罚法》第二十九条第二项，行为人违法对计算机信息系统功能进行删除等行为的，若该行为并未造成这一系统不能正常运行的实害结果，则其不构成应予行政处罚的违法行为，不产生惩戒性法律责任；[134]根据《治安管理处罚法》第三十六条，行为人擅自进入铁

[130] 参见张淑芳：《行政处罚实施中违法行为的纠正途径》，载《法学》2013 年第 6 期，第 141-143 页。
[131] 江苏省高级人民法院行政判决书(2013)苏知行终字第 0004 号。
[132] 山东省高级人民法院行政判决书(2020)鲁行再 27 号。
[133] 熊樟林：《行政违法真的不需要危害结果吗？》，载《行政法学研究》2017 年第 3 期，第 33-43 页。
[134] 《治安管理处罚法》第二十九条：“有下列行为之一的，处五日以下拘留；情节较重的，处五日以上十日以下拘留：（二）违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行的……”

中国知网 https://www.cnki.net

路防护网的，若其行为并未产生影响行车安全的危险，则该行为同样不产生惩戒性法律责任，从而无需考虑《行政处罚法》第三十三条中所规定的免罚事由。[135]

故《行政处罚法》第三十三条所规定之“无危害性不罚”，仅适用于不以危害结果或者危险状态为处罚前提的违法行为。在不要求危害后果的行为中，行政机关也必须考量行为情节轻重，对满足“违法行为轻微”、“及时改正”、“没有造成危害后果”要件的违法行为，依法免予行政处罚。对于该类行为，只有当行为人对法律所保护的利益创造了较为现实具体的危险状态，或者直接引发了侵害结果的发生，才能认为该行为产生了危害结果，否则应认定其“没有造成危害后果”。在“茂名某公司案”中，行为人违反了《固体废物污染环境防治法》第一百二十条中关于废弃物转移联单填写和运行的相关规定，[136]未依法填写和运行危险废弃物转移联单。该条款所保护的法益为生态环境安全，而行为人长期填写自制转移联单并按照规定处置飞灰、申报相关情况，既未造成对生态环境安全的损害，也未产生生态环境安全的危险状态，因此，审理法院认定其行为轻微、未造成危害后果。[137]而在“罗某某案”中，行为人违反《道路交通安全法》第四十四条的规定，驾驶机动车多次不按交通标线行驶。尽管该行为并未产生实际的损害结果，但其引发交通事故的可能性较大，带来了危及道路交通安全的具体现实的危险状态。因此，法院据此认定其行为具有危害结果并无不当。[138]

在实务中，由于实害结果是具体发生的，因此是否造成实害结果的认定往往不存在争议。“具体而现实的危险状态”较为抽象，缺乏清晰明确的判断标准，因此，对于未产生实害结果的行为是否引发了危险状态，在实践中往往存在较大的争议。熊樟林教授指出：“判断相对人行为是否具有危险，应以事后查明的行为时所存在的各种事实为基础，以行为时为标准，从一般人的立场出发来判断。”从一般人的立场出发，具有较大可能造成法益减损的，则该行为产生了危害后果，反之，则该行为未造成危害后果。

[135] 《治安管理处罚法》第三十六条：“擅自进入铁路防护网或者火车来临时在铁路线路上行走坐卧、抢越铁路，影响行车安全的，处警告或者二百元以下罚款。”

[136] 《固体废物污染环境防治法》第一百二十条第一款规定：“违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（五）未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的……”

[137] 广东省高级人民法院：“2019 年度广东法院行政诉讼十大典型案例”，广东法院网，https://www.gdcourts.gov.cn/index.php?v=show&cid=170&id=55546，最后访问时间 2022 年 12 月 23 日。

[138] 江西省高级人民法院行政判决书(2017)赣行申 314 号。

中国知网 https://www.cnki.net

二、一事不再罚

随着法治理念的推进和对于法律安定性的需要，从法治国家的基本权利保障机制出发限制国家公权力的行使，禁止国家对人民的同一行为以相同或类似措施进行处罚已达成普遍共识。[139]这一理念在我国《行政处罚法》得到体现，根据《行政处罚法（2021）》第二十九条，对于同一个违法行为，当其违反多个行政处罚性法律规范时，行政机关只能进行一次罚款，而不能多次重复给予罚款。[140]由此，“一事不再罚”成为我国法定免罚事由之一。

（一）关于“一事”的认定

对于“同一个违法行为”的认定，在理论上，主要存在目的动机说、法律事实说、构成要件说。其中，目的动机说将判断焦点放在行为人的主观动机上，认为一个违法行为是指同一行为人基于同一目的和动机而实施的，能够构成且只能构成一个完整的行为过程的违法行为。[141]法律事实的判断着眼于自然状态下的行为个数，认为同一个违法行为即自然状态下的同一个违法事实。[142]而构成要件说则认为，对于违法行为个数的判断，在于其满足的构成要件个数，其符合几个违法行为的构成要件，则视为其构成几个违法行为。[143]对此，本文认为，同一行为之所以形成法规竞合，正是由于其在不同方面满足了多个法条对于违法构成的要求，即一个自然事实构成了法律规范上的不同违法行为。例如在“王某某诉光山县环境保护局环保行政处罚行政纠纷案”中，行为人王某某在畜禽养殖的过程中，其养殖污染物排放同时造成大气和水污染。若以构成要件说作为判断标准，则其既违反了《大气污染防治法》，构成污染大气的违法行为；又违反了《水污染防治法》，构成污染水源的违法行为，应将其视为两个不同违法行为，分别进行罚款处罚。[144]这一处理方式与民众对于“一事”的理解相悖，难以获得相对人的认可、发挥行政处罚的教育、引导和预防功能；同时也易于导致《行政处罚法》“一事不再罚”的处罚适用规则落空，导致多头罚款、重复罚款等执法问题的出现。以“法律事实说”辅之以“目的动机说”进行判断，或为更具可行性、更符合立

[139] 参见陈红：《行政法与行政诉讼法》，厦门大学出版社 2006 年版，第 183 页。
[140] 《行政处罚法（2021）》第二十九条规定：“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。”
[141] 最高人民法院行政审判庭：《<中华人民共和国行政处罚法>释义与讲座》，警官教育出版社 1996 年版，第 49 页。
[142] 参见方世荣、石佑启主编：《行政法与行政诉讼法》，北京大学出版社 2005 年版，第 267 页。
[143] 参见全国人大常委会法制工作委员会国家法行政法室编著：《<中华人民共和国行政处罚法>释义》，法律出版社 1996 年版，第 67 页。
[144] 河南省潢川县人民法院一审行政判决书(2015)潢行初字第 1 号。

中国知网 https://www.cnki.net

法原意的选择，既能解决“法律事实说”排除当事人的主观状态的弊端，亦有助于解决“目的动机说”欠缺可操作性性和可识别性的问题。同时，这一处理方式有助于解决多头处罚的问题，规范行政权的行使，也更符合民众对于“一事”的认知。因此，一个违法行为可以界定为同一行为主体在紧密连接的同一时间空间内，基于同一意思而实施的一次行为。[145]

这一认定思路在司法实践中得到了广泛的运用。通过梳理当前“一事不再罚”的相关司法案例，可以发现，对于一事的认定主要包含以下要素：同一行为主体、在具有连续性的一段时间内、以一个主观目的实施自然状态下的一个违法事实。例如，在“南阳某旅行社有限公司诉南阳市工商行政管理局宛城分局工商行政管理案”中，对于行为人某旅行社有限公司及其下属两个服务网点在店中放置宣传彩页、构成虚假宣传的行为，工商局分别立案查处，并分别作出三次罚款。对此，法院认为，经营额是对虚假宣传行为处以罚款的重要依据，在本案中，各网点的经营额都需上交原告某旅行社有限公司，而不具有独立的财产，不能独立承担财产责任。因此，三次罚款实质上均由原告承担，相当于原告就同一事项、同样数额的经营额重复地受到了三次罚款的处罚，违反了“一事不再罚”的法律原则和规定，应予以撤销。[146]在“王某某诉光山县环境保护局环保行政处罚行政纠纷案”中，光山环保局主张原告王某某对养殖生猪产生的粪便未采取污染防治措施，构成排放恶臭气体与其向养殖场门前水沟内排放废水两个各自独立的违法行为。对此，法院认为，导致大气和水污染这些结果产生的，为王某某在生猪养殖过程中未对污染物进行处理即对外排放的行为，应视为一个违法行为。[147]

（二）关于“不再罚”的适用

正确适用“一事不再罚”规则的另一关键要素在于对“不再罚”的理解。当前，我国《行政处罚法》第二十九条对于“再罚”的限制，仅限于“罚款”，而不包含其他种类的行政处罚。根据该条款，对“不再罚”可以从以下两方面加以把握。

一方面，对于同一个违法行为，对行为人只能处以罚款数额较高的一个罚款，行为人因违反多个法律规范而应承受的其他罚款得以免除。一是同一个行政机关不得就行为人的同一个违法行为作出多个罚款的行政处罚。例如，在“王某某诉光山县环境

[145] 参见马怀德《<行政处罚法>修改中的几个争议问题》，载《华东政法大学学报》2020 年第 4 期，第 14 页。
[146] 河南省南阳市中级人民法院二审行政判决书（2017）豫 13 行终 391 号。
[147] 河南省潢川县人民法院一审行政判决书(2015)潢行初字第 1 号。

中国知网 https://www.cnki.net

保护局环保行政处罚行政纠纷案”中，由于王某某养殖生猪、未依法处理生猪排泄物造成大气污染和水污染，光山环保局先后就两项污染作出罚款4万元和3万元的行政处罚。对此，法院认为，同一个行为产生两个危害后果、导致两种法律责任产生的，行政机关应根据当事人的情节等，综合确定最终的罚款数额，或作出不同种类的行政处罚，因此，该处罚违反了《行政处罚法》关于“一事不再罚”之规定。[148]二是，一个行为同时触犯了多个法律规范，多个行政机关可以分别予以处罚的，应当“按照罚款数额高的规定处罚”，而不得分别给予罚款处罚。“择一重罚”有助于避免“先罚有效，后罚无效”规则所导致的处罚结果具有随机性的问题，从而实现过罚相当的实质正义要求，但其适用在实践中仍存在一定的困难。行政机关在确定具体罚款数额的过程中往往具有一定的裁量权，只有结合具体案情，才能够对数额高低作出明确认定；但行政处罚实施机关客观上也没有能力对其他领域的法律规范予以准确了解和适用。因此，对于侵害多个法益的同一个违法行为，单个行政机关在进行认定时，往往难以确定是否该法益所指向的罚款数额为较高的数额。对此，学者建议：“对于罚款数额高低的法律适用问题，可能有赖于执法机关根据本法第二十五条的规定，通过行政执法职务协助协商制度解决。”[149]

另一方面，行为人因同一个违法行为违反多个法律规范，除罚款外仍应受到其他种类行政处罚的，不得免除其他种类的处罚。例如，在“湖北省武汉市东湖新技术开发区人民检察院督促保护矿产、林地和耕地资源行政公益诉讼案”中，行为人非法采矿，并造成林地与耕地的破坏。湖北省武汉市东湖新技术开发区人民检察院（以下简称东湖高新区检察院）经调查发现，东湖高新区自然资源局仅对行为人的毁林行为进行了罚款处罚，而未对非法采矿、破坏耕地等问题未依法进行处罚。对此，该检察院认为，尽管非法采矿行为与毁林之间具有结果牵连关系，但该行为同时违反了《矿产资源法》和《森林法》，侵犯了两个法益，且法律规范中所确定的行政处罚的种类也并不相同，因此对于行为人不适用“一事不再罚”，区自然资源局对非法采矿行为不予行政处罚构成怠于履职的违法情形。[150]

综上，“一事不再罚”构成我国行政处罚上的一个法定免罚事由，行为人因同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚，免除

[148] 河南省潢川县人民法院一审行政判决书 (2015)潢行初字第1号。
[149] 杨伟东：《中华人民共和国行政处罚法理解与适用》，中国法制出版社2021年版，第105-106页。
[150] 最高人民检察院：“2022年度“公益诉讼守护美好生活”典型案例”，最高人民检察院官网，https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202302/t20230227_604248.shtml，最后访问时间2023年4月6日。

中国知网 https://www.cnki.net

行为人其他罚款处罚。

第二节 裁量免罚事由

时代不断发展，行政处罚应因时代而变迁，如果毫无例外地恪守处罚法定原则，则将难以应对现实生活中千差万别的个案，陷入行政处罚中个案不公正之困境。[151]针对该问题，德国以及我国台湾地区以便宜主义原则予以回应。[152]行政处罚上的便宜主义原则即尽管行为人的行为已经符合违反行政法上义务之构成要件，具有可罚性，但行政机关仍得以衡量具体情况，审酌决定不予追诉处罚。[153]我国《行政处罚法（2021）》第三十三条第一款在原有法定不罚事由的基础上，增加了“首违可以不罚”这一裁量免罚事由。[154]除此之外，部分行政处罚性法律规范中也赋予了行政机关一定的决定裁量权，使其得根据个案之具体细节，确定是否对行为人处以行政处罚。我国的裁量免罚事由主要有以下情形。

一、首违可以不罚

根据《行政处罚法》第三十三条第一款，这一裁量免罚事由包含了三个要件，一是“初次违法”，二是“危害后果轻微”，三是“及时改正”。由于在上文中已对“及时改正”这一要件展开讨论，本部分内容主要对其余两个要件在实践中的认定进行探讨。

（一）“初次违法”

“初次违法”是首违不罚的首要条件，只有满足这一条件，才有继续探讨其余要件的必要。[155]但由于缺乏国家法层面的规定，对于“初次”的认定，交由个具体执法部门确定。对于从“初次违法”主要存在三种理解：一是违法行为初次发生，二是违法行为初次被执法机关发现，三是双重“首次”，即该行为既初次被行政机关发现，又属于违法行为首次发生。[156]

---

[151] 参见金成波：《行政处罚便宜原则研究》，载《华东政法大学学报》2022 年第 2 期，第 142 页。

[152] 《德国违反秩序法》第 47 条第 1 款规定：“追究机关通过与其义务相符的裁量对违反秩序行为进行追究。在程序由该行政机关进行期间，该机关可以停止程序。”——郑冲译：《德国违反秩序法（续）》，《行政法学研究》1995 年第 2 期，第 89 页；我国台湾地区“行政罚法”第十九条第一款规定：“违反行政法上义务应受法定最高额新台币三千元以下罚锾之处罚，其情节轻微，认以不处罚为适当者，得免予处罚。”——熊樟林编：《中外行政处罚法汇编》，北京大学出版社 2021 年版，第 26 页。

[153] 陈清秀著：《行政罚法》，法律出版社 2016 年版，第 63 页。

[154] 《行政处罚法（2021）》第三十三条第一款规定：“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。”

[155] 张红、岳洋：《行政处罚“首违不罚”制度及其完善》，载《经贸法律评论》2021 年第 3 期，第 28 页。

[156] 参见江国华：《“首违不罚”的法理与适用——兼议新<行政处罚法>第 33 条第 1 款之价值取向》，载《湖北社会科学》2021 年第 3 期，第 144 页。

中国知网 https://www.cnki.net

在实践中，对于单一的违法行为，“初次违法”主要是指首次被执法机关发现的违法行为，即该行为人无同一违反法律、法规规定被查处的记录。[157]例如，在“赵某某案诉连云港市市场监督管理局行政处罚案”中，二审法院认为，执法机关连云港市场监管局未能提供相应证据，证明行为人存在多次同类违法行为，因此应认定行为人为初次违法。[158]

对于连续性违法行为，是否将“执法机关首次出现”视为“初次违法”，在实践中存在不同的观点。其中一种观点认为，在一段时期内，行为人多次实施若干个性质相同的违法行为、受到行政机关追究的，其行为不属于“初次违法”。例如，在“乐山驳骨堂骨科医院诉乐山市市中区市场监督管理局药品行政处罚案”中，行为人主张其初次由于自制并销售医用制剂而受罚，属于“初次违法”之情形。对此，二审法院认为，经行政机关调查核实，该行为人自 2017 年 1 月至 2018 年 8 月 14 日期间持续无证配制以假药论处的药酒、硬膏、中药液，并用于不特定患者，其违法行为不属于“初次违法”之情形。[159]另一种观点认为，违法行为持续时间较短的，即便在该时间段内行为人存在继续性违法行为，只要其在一定期限内不存在记录在案的违反同一违法行为的记录，则应其视为“初次违法”。例如，在“遂宁市大英县某猪肉摊超出限定区域销售小型生猪屠宰场点的生猪产品案”中，行政机关认为，当事人之行为违反《四川省生猪屠宰管理办法》第六条第三款“小型生猪屠宰场点的生猪产品仅限于向本地市场供应。本地市场的具体区域范围由所在市（州）人民政府在审批小型生猪屠宰场点时根据当地实际核定”之规定，但其违法行为持续时间不足一个月，经查系 3 年内首次违反市场监管领域法律法规，且其行为轻微未造成危害后果、及时改正，符合“首违不罚”的相关规定，从而对其不予行政处罚。[160]尽管在理论上继续性违法行为已构成多次违法，但对于情节轻微、危害后果轻微的违法行为，对其适当放宽“初次违法”之认定标准，适当将首次发现、在一段时间违法次数较少的违法行为，认定为初次违法之行为，有利于实现“处罚与教育相结合”的目标，从而鼓励和引导行为人纠正其违法行

[157] 例如，《海南省人力资源和社会保障领域实施包容免罚清单》规定：“初次违法是指根据相关行政机关查询记录，无同一违反法律、法规规定被查处的记录”；《（上海市）市场轻微违法违规经营行为免罚清单》（五）规定：“一、下列轻微违法行为，及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚：……（五）违反《中华人民共和国广告法》第九条第（三）项，广告中使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语，但广告是在广告主自有经营场所或者互联网自媒体发布，且属于首次被发现的。”

[158] 江苏省连云港市中级人民法院行政判决书(2021)苏 07 行终 48 号。

[159] 四川省乐山市中级人民法院行政判决书(2019)川 11 行终 151 号。

[160] 四川省人民政府：“《以有温度的执法助企纾困 四川公布市场监管领域“首违不罚”十大典型案例》”，四川省人民政府官网，https://www.sc.gov.cn/10462/10464/13722/2022/10/14/75db30ec03a1466b9f9e961c2a9ac18a.shtml, 最后访问时间 2022 年 12 月 19 日。

中国知网 https://www.cnki.net

为，为市场主体营造宽松和谐的法治营商环境。

此外，根据向前追溯期限的长短，对于“初次违法”的认定又可以区分为无限期向前追溯的认定以及有限期向前追溯的认定。[161]适用无限期向前追溯认定的，一经其行政机关发现并查处特定违法行为，行为人在之后其再次实施同一违法行为的，不再构成“初次违法”。在目前的行政处罚实践中，往往采用的是无限期向前追溯的认定方式。有限期向前追溯的，在周期期限届满后再次实施违法行为的，视为“初次违法”，而得以适用“首违可以不罚”条款。例如，《四川省市场监管领域“首违不罚”清单适用规则》明确，明确“首次违法”的认定条件为“三年内首次违反市场监管领域法律法规规章的”；《长江三角洲区域税务轻微违法行为“首违不罚”清单》明确“首次违法”的认定条件为“当事人在一年内首次违法的”。无限期向前追溯的认定方式，有助于加强严格监管，在给予行为人改过机会的同时，防范行为人再犯；有限期向前追溯的认定方式，则有助于减轻地方行政执法的负担，营造更为宽松的法治环境。因此，对于采用无限期抑或有限期的向前追溯方式、以及向前追溯期限的长短，应根据具体的行政处罚领域而确定。通常而言，对于新业态、以及行为性质轻微，危害性不大的行为，可以采取更为宽容的态度，适用较短周期的“首违不罚”；而对于行为性质严重，违法行为潜在危害性更大的行为，则采取更为谨慎的监管态度，适用较长周期或者无限期向前追溯的“首违不罚”。

（二）危害后果轻微

如前所述，危害后果包括违法行为产生的实害后果以及现实具体的危险状态。“危害后果轻微”意味着行为并非不具有任何危害性，而是产生了一定的危害后果，但其所产生的实害结果轻微、该危险状态潜在的危害性也较小。目前国家法层面缺乏对该要件明确的判断标准，因此“危害结果轻微”多交由地方行政机关在具体领域的的行政执法实践中加以认定。从目前公布并实施的“免罚清单”、“不予处罚规定”等规范性文件以及“首违不罚”案件来看，对于危害后果轻微与否的认定主要有以下几种处理方式。一是以危害后果及社会影响的明显与否作为判断的标准，从而不具有明显危害后果和不良社会影响构成“首违不罚”的必要条件；[162]二是以危害后果的主动减轻

[161] 参见张红、岳洋：《行政处罚“首违不罚”制度及其完善》，载《经贸法律评论》2021 年第 3 期，第 28 页。

[162] 例如，《岱山县人民政府办公室关于印发岱山县行政执法多领域“首错免罚”清单模式实施办法的通知》第五条规定：“适用“首错免罚”清单模式的案件应同时具备以下条件：（一）违法行为情节轻微，没有造成明显危害后果或不良社会影响的；（二）属于首次违法，且当事人无主观故意的；（三）当事人承诺整改，且具备整改条件的；（四）列入“首错免罚”事项清单的”；《珠海市人力资源和社会保障局规范行政处罚自由裁量权规定(第二版)》第八条规定：“……危害后果轻微的认定应至少同时满足第（六）（七）（八）项条件：（六）危害后果可以完全消除

中国知网 https://www.cnki.net

和消除为判断标准，能够主动减轻和消除实害后果及社会影响的，得认定为危害后果轻微；[163]三是列举危害国家利益及社会公共利益、危及生命健康或公共安全等不属于危害后果轻微的负面清单，以缩小认定的范围；[164]四是明确危害后果轻微的考量因素，并要求在认定的时候综合考虑。其中，主要考量因素有危害程度轻重、危害范围大小、危害后果是否易于消除或减轻、行为人是否主动消除或者减轻危害后果、行为人与受害人是否达成和解。[165]

危害后果是对于法益的侵害后果以及带来的风险状态。因此，认定危害后果轻微，应围绕着特定行政法律规范所保护的利益、法律关系、法律秩序展开，而不能仅因违法行为产生的“社会影响”而认定其不属于“危害后果轻微”的行为。此外，危害后果轻微是在危害后果已产生的情况下进行的认定，其是否容易减轻或消除是应予考量的因素之一，但仅仅因为其不能够消除即全盘否认其存在轻微的可能性，这一做法缺乏合理性。在上述四种处理方式中，第四种处理方式综合考虑各种可能的影响因素，较为全面、可操作性强，对于当下的行政机关认定“危害性轻微”具有较强的借鉴意义。例如，在“遂宁市大英县某猪肉摊超出限定区域销售小型生猪屠宰场点的生猪产品案”中，行为人超出行政许可经营地点范围售卖生猪产品，违反了《四川省生猪屠宰管理办法》第六条第三款之规定，对生猪售卖市场秩序造成扰乱。但考虑其违法行为持续时间较短、且其所售猪肉进货来源手续齐全、检验检疫证章齐全，未造成防疫问题以及食品安全问题，危害程度轻，且行为人积极配合调查改正，行政机关认为其符合“首违”不罚之危害后果轻微的条件。[166]

的；（七）未引发群体性事件的；（八）未造成社会影响的。”

[163] 例如，《江西省市场监管领域轻微违法违规经营行为不予处罚指导意见》（二）规定：“危害后果轻微：违法行为有特定对象的，造成特定对象一定程度的人身伤害、财产损失，但当事人与特定对象已经达成和解，可以认定为危害后果轻微；违法行为没有特定对象的，造成一定社会影响，但当事人及时采取措施，消除或者减轻社会影响的，可以认定为危害后果轻微。”

[164] 例如，《宁波市公安局关于印发宁波市公安行政执法领域适用首违不罚实施办法(试行)的通知》第四条规定：“违法行为具有下列情形之一的，不属于危害后果轻微：（一）涉及国家利益或社会公共利益的；（二）可能危及生命健康或公共安全的；（三）在发生自然灾害、事故灾难、公共卫生事件或者社会安全事件等突发事件时或突发事件预警期内，不配合突发事件应对措施的；（四）造成较大社会影响的。”

[165] 《江苏省市场监督管理局关于印发江苏省市场监管领域轻微违法行为不予处罚和从轻减轻处罚规定的通知》：“危害后果轻微，可以结合下列因素综合认定：（一）危害程度较轻，如对市场秩序的扰乱程度轻微，对消费者欺骗、误导作用较小等；（二）危害范围较小；（三）危害后果易于消除或者减轻；（四）主动消除或者减轻违法行为危害后果；（五）主动与违法行为对象达成和解；（六）其他能够反映危害后果轻微的因素。”此外，《（山西省）药品食品监管领域轻微违法行为不予处罚规定（试行）》等也有类似的规定。

[166] 四川省人民政府：“《以有温度的执法助企纾困 四川公布市场监管领域“首违不罚”十大典型案例》”，四川省人民政府官网，https://www.sc.gov.cn/10462/10464/13722/2022/10/14/75db30ec03a1466b9f9e961c2a9ac18a.shtml, 最后访问时间 2022 年 12 月 19 日。

中国知网 https://www.cnki.net

二、附条件可以不罚

除了《行政处罚法》关于“首违可以不罚”之规定以外，部分行政处罚性法律规范亦规定了附条件的裁量免罚事由。行为人符合一定条件的，行政机关得根据其行为事实、性质、情节和社会危害等，在个案中具体确定是否对当事人免予行政处罚。当前，主要的附条件免罚事由主要包括与受害人和解并履行赔偿义务、主动参加社会服务等。

一是与受害人和解并履行赔偿义务可以不罚。在部分仅涉及财产纠纷的轻微违法行为案件中，经行政机关调解或者当事人自行和解后，双方当事人能够达成一致，并且义务履行方能够全部履行其义务的，行政机关可以依法对其不予行政处罚。例如，根据《广东省劳动保障监察条例》、《重庆市劳动保障监察条例》等，人力资源保障行政部门对于金钱给付等投诉案件，组织调解后双方当事人达成一致意见并全部履行的，视情节轻重依法不予处罚或者减轻对用人单位的处罚。根据《厦门经济特区知识产权促进和保护条例》，除了涉嫌知识产权犯罪的知识产权纠纷案件，双方纠纷达成和解协议或者调解协议，且不损害第三方利益和公共利益并实际履行的，行政机关可以视情节对其从轻、减轻或者不予行政处罚。对于该类违法行为，之所以存在不罚事由，主要有两个原因：一是其损害的主要是个体的利益，而较少或者几乎未损害到公共利益，在行为人及时补救违法行为、履行财产赔付义务的情况下，违法行为的危害后果得以减轻乃至消除；二是从实质化解社会纠纷案件的角度来看，对于履行赔付义务的行为人不予处罚，有助于鼓励行为人积极与第三人协商，履行其金钱给付义务及其他损害赔偿义务，化解双方矛盾，防范社会性事件的产生，维护社会稳定与和谐。

二是主动参加社会服务可以不罚。对于部分轻微违法行为，应受到行政处罚的个人自觉履行法定义务，并自愿参加社会服务活动的，行政机关可以依法对其不予行政处罚。例如，根据《成都市生活垃圾管理条例》第十八条，个人违反该条例之规定，未在指定地点分类投放生活垃圾，应当受到处罚的个人，自愿参加并完成相应的生活垃圾分类社会服务活动，经城市管理部门核准，可以依法从轻、减轻或者不予行政处罚。根据《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百二十五条，违法行为人违反特定条例应受到行政处罚，其自愿协助维护交通秩序的，可以免予罚款处罚。[167]参加

[167] 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百二十五条规定：“违反本条例第五十八条、第五十九条第一款第一项和第二款规定的，由市公安机关交通管理部门处一百元罚款；违法行为人自愿协助维护道路交通秩序超过两小时的，可以免予罚款处罚。违反本条例第五十九条第一款第二项规定的，由市公安机关交通管理部门给予警告或者

中国知网 https://www.cnki.net

社会服务作为一种对于轻微违法行为的处罚替代措施，能够实现维护社会秩序和公共利益的目的，有助于节约执法成本，帮助行为人意识到自身的违法错误并积极改正、修复其违法行为所侵害的社会秩序。

除上述事由之外，部分地方法规中还规定了“主动披露可以不罚”、“受他人胁迫可以不罚”、“经法益衡量可以不罚”等事由。对于裁量免罚事由，尽管法律法规以“可以”二字的授权表述，赋予了行政机关处罚决定裁量权，但行政机关仍应坚持过罚相当原则、比例原则等基本原则，依据违法行为的事实、性质、情节以及危害程度等因素，合理裁量，综合作出罚或不罚的判断，并积极教育、引导、督促行为人自觉守法。

处二十元以上一百元以下罚款；违法行为人自愿协助维护交通秩序的，可以免予罚款处罚。具体执行标准由市公安机关交通管理部门制定并向社会公布。违反本条例第五十九条第一款第四项规定的，由市公安机关交通管理部门处二百元罚款；违法行为人自愿协助维护交通秩序超过四小时的，可以免予罚款处罚。”

中国知网 https://www.cnki.net

结语

在不予行政处罚事由亟需体系化和规范化的背景下，对不予行政处罚事由进行归纳与分类具有必要性。本文从法律责任的产生与实现这一视角出发，根据行政法律责任的不同状态，把当前法律规范中明确的与行政处罚实践中常见的不予行政处罚事由分为三个维度：违法构成缺失事由、法律责任消灭事由、免予行政处罚事由。这三个维度的事由，分别对应着法律责任的不同状态，即法律责任未产生、法律责任消灭、法律责任持续但得以免除。相较于列举式分析以及以违法性有无为划分标准的二分式分析等方法，这一类型化分析进路一方面能够充分提炼不同事由之间的共性与差异，呈现不予行政处罚事由背后的法理蕴含；另一方面契合了《行政处罚法》关于行政处罚决定作出的逻辑，并以“法律责任”为核心，进一步厘清了行政处罚的内在脉络，有助于为行政执法和司法实践提供明确指引，并为立法规则的设立和完善提供有益参考。在该不予行政处罚事由的类型化框架下，对于罚与不罚的考虑，是一个层层递进的过程（如图 1 所示）。其中，违法行为的成立是行政处罚的前提，法律责任的持续是行政处罚的基础，而免予行政处罚事由的存在与否是行政处罚作出前的必要考虑因素。因此，对于违反客观法律规范的行为人，当且仅当其不具有违法构成缺失事由、行政法律责任消灭事由、免予行政处罚事由，方能对其加以行政处罚。需要注意的是，行政法律责任的消灭，不仅可能发生在行政处罚决定作出前，同样可能发生在行政处罚决定作出后，例如违法行为人在处罚决定作出后死亡等。由于本文主要通过不予行政处罚事由的类型化探讨行政处罚决定的作出路径，因此并未对处罚决定作出后的责任消灭加以展开论述。此外，对于不同类型的不予行政处罚事由，由于其背后的法理基础不同，其不罚形式应有所区别，并具体体现在不予行政处罚决定中，否则可能为行为人带来不应有的负担。然囿于文章主题与所搜集材料的限制，相关具体制度设计尚待进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

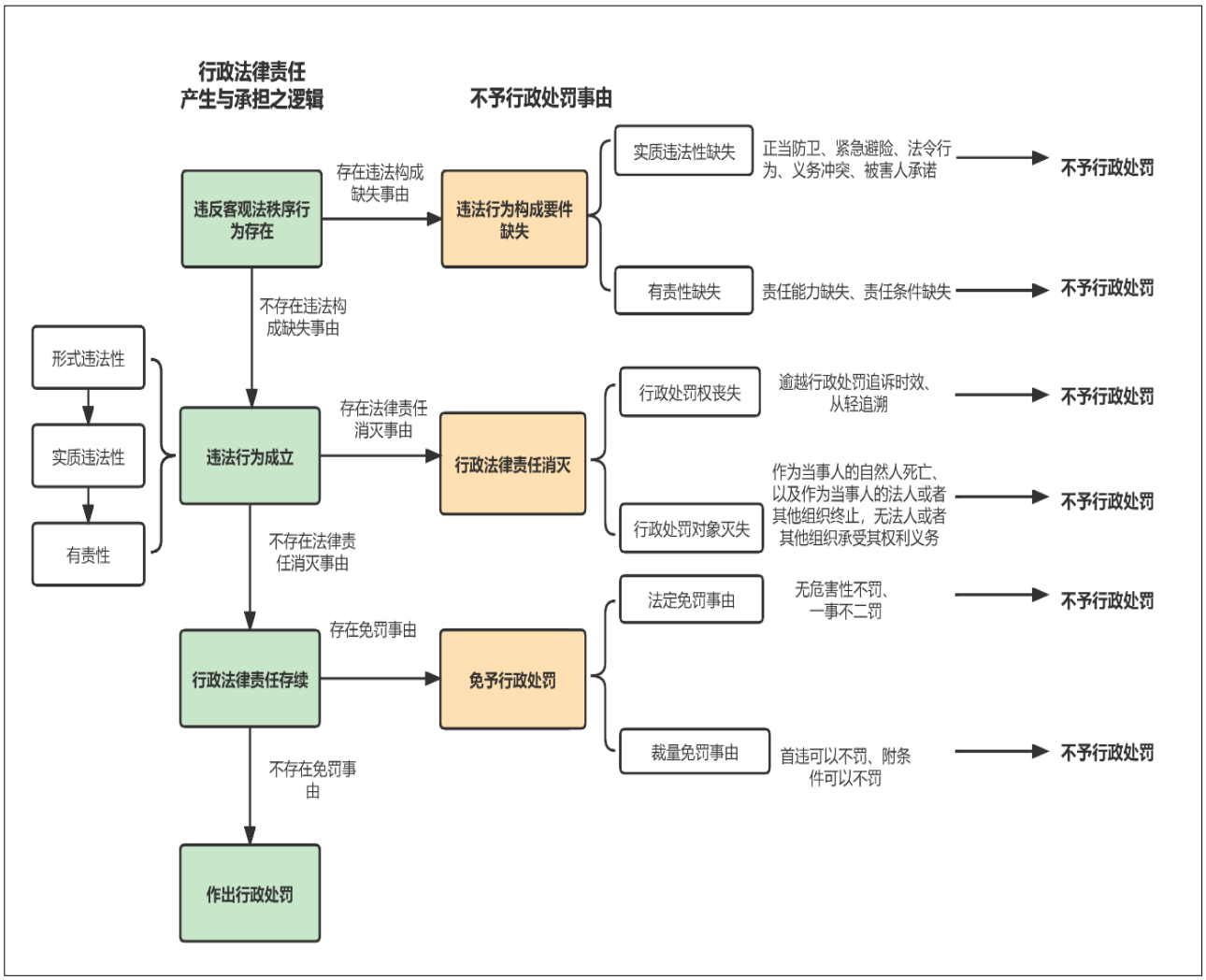


图 1 不予行政处罚事由类型化视角下作出行政处罚决定的路径

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

1. 著作类：

[1] [德]黑格尔. 范扬、张全泰译. 法哲学原理[M].北京：商务印书馆,1961:119.

[2] 曹康泰. 行政处罚法教程[M]. 北京：中国法制出版社, 2011:97-98.

[3] 陈红. 行政法与行政诉讼法学/21 世纪东部法学系列教材[M]. 厦门：厦门大学出版社, 2006:183.

[4] 陈清秀. 行政罚法. [M]. 北京：法律出版社,2016:63、110、118、134-135、308、313.

[5] 方世荣、石佑启. 行政法与行政诉讼法. [M]. 北京：北京大学出版社, 2015:267.

[6] 高铭暄. 刑法学. [M]. 北京：北京大学出版社、高等教育出版社,2019:134.

[7] 关保英. 行政处罚法新论[M]. 北京：中国政法大学出版社, 2007:166.

[8] 洪家殷. 行政罚法论[M]. 台湾: 五南图书出版公司, 2006: 61.

[9] 全国人大常委会法制工作委员会国家法行政法室. 《中华人民共和国行政处罚法》释义[M]. 北京: 法律出版社, 1996: 67.

[10] 熊樟林. 中外行政处罚法汇编. [M]. 北京：北京大学教育出版社,2021:105.

[11] 晏山嵘. 行政处罚实务与判例释解[M]. 北京：法律出版社, 2016:241-251.

[12] 杨伟东. 中华人民共和国行政处罚法理解与适用[M]. 北京：中国法制出版社, 2021: 105-106.

[13] 应松年. 行政行为法[M]. 北京: 人民出版社, 1993:473.

[14] 张明楷. 刑法学. [M]. 北京：法律出版社, 2016:198、221.

[15] 最高人民法院行政审判庭. 《中华人民共和国行政处罚法》释义与讲座. [M]. 北京：警官教育出版社, 1996:49.

2. 期刊类：

[1] 黄锫.应受行政处罚行为成立要件的法理构造[J].浙江学刊,2022(02):47-49.

[2] 江必新. 论应受行政处罚行为的构成要件[J]. 法律适用, 1996(6):4.

[3] 江国华,丁安然.“首违不罚”的法理与适用——兼议新《行政处罚法》第 33 条第 1 款之价值取向[J].湖北社会科学,2021(03):144.

[4] 姜明安.行政违法行为与行政处罚[J].中国法学, 1992(6): 42.

[5] 金成波.行政处罚便宜原则研究[J].华东政法大学学报,2022,25(02):142.

[6] 金成波.行政处罚中违法者主观认识论纲[J].当代法学,2022,36(04):105.

[7] 马怀德.《行政处罚法》修改中的几个争议问题[J].华东政法大学学报,2020,23(04):10.

[8] 孙秋楠. 受行政处罚行为的构成要件[J]. 中国法学, 1992(6):47.

中国知网 https://www.cnki.net

[9] 汪永清.关于应受行政处罚行为的若干问题[J].中外法学,1994(02):20、24-25.

[10] 王志平.论行政处罚适用的构成要件[J].现代法学,1997(05):88-89.

[11] 谢红星.不予行政处罚的法理——围绕《行政处罚法》第 33 条而展开[J].广东社会科学,2022(02): 241-251.

[12] 谢红星.不予行政处罚行为的确定[J].学术界,2022(07): 67-69.

[13] 熊樟林.论行政处罚上的违法性阻却事由[J].行政法学研究,2022(04):13-26.

[14] 熊樟林.行政违法真的不需要危害结果吗?[J].行政法学研究,2017(03):33-43.

[15] 杨东升,刘恺.论行政处罚主观过错归责原则——《行政处罚法》(修订二审稿)第 31 条评析[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2020,51(06):79.

[16] 尹培培.不予行政处罚论——基于我国《行政处罚法》第 27 条第 2 款规定之展开[J].政治与法律,2015(11):149-160.

[17] 尹培培.论新《行政处罚法》中的“主观过错”条款[J].经贸法律评论,2021(03):50-62.

[18] 张红,岳洋.行政处罚“首违不罚”制度及其完善[J].经贸法律评论,2021(03):28.

[19] 张红.免予行政处罚制度的现实困境与解决之道[J].中国司法,2020(04):60.

[20] 张淑芳.免罚清单的实证与法理[J].中国法学,2022(02):243-263.

[21] 张淑芳.行政处罚实施中违法行为的纠正途径[J].法学,2013(06):141-143.

[22] 周苏湘.论“不予行政处罚”的逻辑内涵及其适用展开[J].行政法学研究,2022(02):56-65.

[23] 周优, 刘琦. 税务执法"首违不罚"的法理阐释与制度完善[J]. 税务研究, 2021(9): 96-101.

3. 裁判文书:

[1] 安徽省高级人民法院行政判决书(2020)皖行终 181 号。

[2] 安徽省高级人民法院行政判决书(2021)皖行终 222 号。

[3] 安徽省合肥市中级人民法院行政判决书(2019)皖 01 行初 195 号。

[4] 北京市第二中级人民法院行政判决书（2014）二中行终字第 106 号。

[5] 北京市第三中级人民法院行政判决书(2020)京 03 行终 209 号。

[6] 甘肃省高级人民法院行政裁定书(2018)甘行申 220 号。

[7] 广东省东莞市第一人民法院行政判决书 （2018）粤 1971 行初 649 号。

[8] 广东省东莞市中级人民法院行政判决书 （2019）粤 19 行终 86 号。

[9] 广东省佛山市中级人民法院行政判决书(2021)粤 06 行终 339 号。

[10] 广东省高级人民法院行政判决书(2019)粤行申 2595 号。

中国知网 https://www.cnki.net

[11] 广东省揭阳市中级人民法院行政判决书(2021)粤 52 行终 14 号。

[12] 广东省肇庆市鼎湖区人民法院行政判决书(2020)粤 1203 行初 107 号。

[13] 河北省石家庄市中级人民法院行政判决书(2020)冀 01 行终 416 号。

[14] 河南省高级人民法院行政裁定书 (2020)豫行申 262 号。

[15] 河南省潢川县人民法院一审行政判决书(2015)潢行初字第 1 号。

[16] 河南省南阳市中级人民法院二审行政判决书（2017）豫 13 行终 391 号。

[17] 吉林铁路运输法院行政判决书(2020)吉 7102 行初 88 号。

[18] 江苏省高级人民法院行政判决书(2013)苏知行终字第 0004 号。

[19] 江苏省连云港市中级人民法院行政判决书(2021)苏 07 行终 48 号。

[20] 江苏省南通市中级人民法院行政判决书(2016)苏 06 行终 461 号。

[21] 江苏省苏州市中级人民法院行政判决书(2019)苏 05 行终 590 号。

[22] 江西省高级人民法院行政判决书(2017)赣行申 314 号。

[23] 金华市婺城区人民法院行政判决书(2014)金婺行初字第 41 号。

[24] 辽宁省鞍山市中级人民法院行政判决书(2020)辽 03 行终 26 号。

[25] 辽宁省朝阳市中级人民法院行政判决书（2015）朝行终字第 00028 号。

[26] 辽宁省营口市中级人民法院行政判决书(2020)辽 08 行终 145 号。

[27] 山东省安丘市初级人民法院行政判决书（2014）安行初字第 22 号；

[28] 山东省高级人民法院行政判决书(2020)鲁行再 27 号。

[29] 山东省高密市人民法院行政判决书(2019)鲁 0785 行初 123 号。

[30] 山东省济南市中级人民法院行政判决书(2014)济行终字第 138 号。

[31] 山东省青岛市中级人民法院行政判决书(2020)鲁 02 行终 443 号。

[32] 山东省潍坊市中级人民法院行政判决书(2014)潍行终字第 112 号。

[33] 上海市第三中级人民法院行政判决书 （2017）沪 03 行终 856 号。

[34] 上海市第一中级人民法院二审行政判决书(2014)沪一中行终字第 266 号。

[35] 上海市闵行区人民法院行政判决书(2018)沪 0112 行初 51 号。

[36] 四川省乐山市中级人民法院行政判决书(2019)川 11 行终 151 号。

[37] 浙江省高级人民法院行政裁定书(2019)浙行申 64 号。

[38] 浙江省杭州市上城区人民法院行政判决书(2008)上行初字第 6 号。

[39] 浙江省平湖市人民法院行政判决书(2015)嘉平行初字第 17 号。

中国知网 https://www.cnki.net